

**El déficit de estándares de valoración probatoria en la justicia electoral
mexicana:
protocolo de administración indiciaria y umbral de suficiencia verificables**

Tesis de Maestría
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales · División de Estudios de Posgrado

Índice

Capítulo 1. Categorías de epistemología jurídica para la prueba por indicios.....	1
1.1. La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional.....	1
1.1.1. La racionalidad probatoria es una conquista histórica y no un rasgo definitorio de la función judicial.....	2
1.1.2. Una epistemología moderadamente realista evita tanto la infalibilidad como el escepticismo.....	3
1.1.3. El modelo cognoscitivista exige enunciados fácticos verdaderos y controlables	5
1.1.4. La epistemología jurídica opera en dos proyectos: describir las reglas y reformarlas.....	7
1.2. La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso.....	8
1.2.1. Sin averiguación de la verdad el derecho fracasa como mecanismo de dirección de conducta.....	9
1.2.2. La verdad de los hechos es condición necesaria, aunque no suficiente, de la justicia de la decisión.....	10
1.2.3. Las concepciones ritual y retórica de la prueba renuncian a la función epistémica.....	11
1.2.4. La verdad procesal es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas.....	12
1.3. La actividad probatoria se descompone en tres momentos.....	14
1.3.1. La conformación del conjunto de elementos de juicio concentra las restricciones jurídicas.....	14
1.3.2. La valoración es el momento de la racionalidad y su resultado es contextual	16
1.3.3. Sin estándar de prueba la valoración no determina decisión alguna.....	17
1.3.4. La distinción de los tres momentos ordena el protocolo y el umbral.....	18
1.4. La inferencia probatoria tiene una estructura identificable.....	19
1.4.1. La prueba se descompone en dos fases y la segunda encadena inferencias	19
1.4.2. Cuatro elementos componen toda inferencia probatoria.....	21
1.4.3. La garantía admite tres fuentes y solo dos de ellas son probatorias.....	22
1.4.4. Explicitar la estructura es lo que vuelve criticable la inferencia.....	23
1.5. La solidez de la inferencia admite criterios de control.....	24
1.5.1. La remisión a la sana crítica es vaga y puede precisarse.....	25
1.5.2. Cuatro criterios controlan los hechos probatorios.....	26
1.5.3. Dos criterios controlan la garantía.....	28

1.5.4. Cinco criterios controlan la hipótesis.....	29
1.5.5. La solidez es gradual y esa graduación es la que un estándar debe medir....	30
1.6. El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos.....	31
1.6.1. Tres objeciones al tratamiento aislado de los elementos de prueba.....	31
1.6.2. El derecho mexicano recogió la objeción holista desde 1974.....	32
1.6.3. El holismo narrativo es peligroso y no puede fundar el protocolo.....	33
1.6.4. La pregunta correcta es por el dominio de cada modelo.....	34
1.7. Libre convicción como principio metodológico negativo; la sana crítica no es criterio	36
1.7.1. Principio negativo versus criterio positivo de valoración.....	36
1.7.2. La desviación histórica: de principio a subjetividad descontrolada.....	37
1.7.3. La sana crítica no es un criterio sino una referencia a máximas de experiencia	38
1.7.4. Un estándar subjetivo no es un estándar.....	39
1.7.5. La exigencia de explicitación como condición de controlabilidad.....	40
1.8. Un estándar subjetivo no es un estándar.....	
1.8.1. Qué requiere un estándar de prueba para serlo.....	
1.8.2. La corrupción histórica de la duda razonable.....	
1.8.3. Dos vías convencionales y sus defectos comunes.....	
1.8.4. El problema de la uniformidad.....	
1.8.5. La función de un estándar en la distribución del error.....	
1.8.6. La conclusión operativa.....	

Capítulo 1

Categorías de epistemología jurídica para la prueba por indicios

SUMARIO: 1.1. *La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional.* 1.2. *La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso.* 1.3. *La actividad probatoria se descompone en tres momentos.* 1.4. *La inferencia probatoria tiene una estructura identificable.* 1.5. *La solidez de la inferencia admite criterios de control.* 1.6. *El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos.* 1.7. *La libre convicción no es un criterio de valoración.* 1.8. *Un estándar subjetivo no cumple la función de un estándar.* 1.9. *La motivación convierte la decisión en objeto de control externo.* 1.10. *Recapitulación.*

1.1. La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional

La valoración de la prueba admite control racional o queda entregada a la conciencia del juzgador, y entre esas dos posibilidades no existe término medio. La elección condiciona todo lo que este trabajo propone, porque un protocolo de administración y un umbral de suficiencia solo tienen sentido bajo la primera. Ambos instrumentos presuponen que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento, susceptible de acierto y de error. Este apartado sostiene que lo es y fija las categorías de la epistemología jurídica que permiten demostrarlo. Tres razones sustentan la conclusión: la racionalidad probatoria fue una conquista histórica y no un rasgo definitorio de la función judicial. El conocimiento de hechos admite, además, un realismo moderado que evita por igual la infalibilidad del juzgador y el escepticismo sobre la prueba. Ese realismo se traduce, por último, en un modelo que exige enunciados verdaderos y controlables desde fuera de la sentencia.

1.1.1. La racionalidad probatoria es una conquista histórica y no un rasgo definitorio de la función judicial

La tradición jurídica trató durante siglos el conocimiento de los hechos como una cuestión pacífica. Gascón Abellán (2010) resume el lema de esa tradición con una fórmula exacta: «Los hechos son los hechos y no necesitan ser argumentados» (p. 11). La confianza descansaba en la evidencia de los hechos, y lo evidente no reclama justificación alguna. La autora advierte, sin embargo, que esa seguridad nunca estuvo presente en todos los modelos judiciales. Sostiene también que la historia del empirismo es la crónica de los intentos y fracasos por encontrar un lugar para el conocimiento empírico dentro de la racionalidad (Gascón Abellán, 2010, p. 11). La premisa tradicional resulta falsa como descripción histórica, y su falsedad no constituye una curiosidad erudita. De ese examen depende el estatuto de toda la propuesta que sigue, porque una racionalidad conquistada es una racionalidad que puede perderse.

Durante un largo periodo la construcción de la premisa fáctica se apoyó en ritos y procedimientos mágicos donde no cabía apelación alguna a la razón. Gascón Abellán (2010) describe esa etapa como una experiencia mística de búsqueda de la verdad. Añade que a veces se trató, más simplemente, de la búsqueda de una decisión aleatoria o de un dictamen sobrenatural, antes que de un método con apariencias de racionalidad (p. 12). El caso característico es la ordalía, entendida en sentido amplio como duelo judicial, ordalía y juicio de Dios (Gascón Abellán, 2010, p. 12). Caminar sobre brasas incandescentes sin sufrir lesión resolvía la imputación, y recoger un anillo sumergido en agua hirviendo producía idéntico efecto. Esas prácticas no averiguaban hechos: los sustituían por un veredicto de origen sobrenatural. El vencimiento en duelo demuestra la fuerza, la destreza o la suerte del reo, pero nada acerca de los hechos imputados. Gascón Abellán (2010) concluye que el proceso se convierte entonces en un medio que constituye la verdad, en lugar de un medio que intenta averiguarla (p. 13). La diferencia entre constituir y averiguar recorre todo este trabajo.

El tránsito hacia la prueba legal tasada mejoró la apariencia de racionalidad sin alterar la estructura del problema. Gascón Abellán (2010) explica que la prueba de ordalía y la prueba legal constituyen supuestos de prueba formal, porque ambas excluyen la libre valoración del juez (p. 14). Una y otra la sustituyen por un juicio infalible y superior, y la diferencia entre un juicio divino y un juicio legal no rompe esa continuidad. La fijación de los hechos en todo sistema tasado adopta, además, un

carácter encubiertamente deductivo. Si la confesión prueba de manera incontrovertible la culpabilidad y el reo confesó, entonces el reo resulta culpable por necesidad lógica. Ese procedimiento no aspiraba a una verdad probable, sino real (Gascón Abellán, 2010, p. 15). El ritual probatorio valía por sí mismo, con independencia de los hechos que decía acreditar.

De esa reconstrucción se sigue una consecuencia que interesa de manera directa a esta investigación. La comprensión de la actividad judicial como operación racional constituye una cualidad asociada a determinada cultura jurídica, y no un rasgo conceptual o definitorio de aquélla (Gascón Abellán, 2010, p. 13). La racionalidad probatoria no viene dada con la función de juzgar: se conquistó a lo largo de siglos y, por lo mismo, puede perderse sin que ninguna norma se derogue. El capítulo segundo documenta un episodio de esa naturaleza en la justicia electoral mexicana. Una práctica valorativa construida durante casi tres décadas dejó de aplicarse allí sin que ningún criterio fuera abandonado de manera expresa. La contingencia histórica de la racionalidad probatoria es, por tanto, el supuesto que vuelve necesaria una propuesta como la presente.

1.1.2. Una epistemología moderadamente realista evita tanto la infalibilidad como el escepticismo

La distinción entre verdad y prueba organiza el problema epistemológico del proceso. La primera designa la correcta descripción de un mundo independiente, y la segunda, la descripción de ese mundo formulada en el proceso (Gascón Abellán, 2010, p. 40). Dos tradiciones cancelaron esa dualidad por caminos opuestos. La ciencia procesal continental las identificó desde una epistemología realista acrítica, según la cual los procedimientos probatorios arrojan resultados infalibles. La tradición del *common law* las canceló desde el extremo contrario, al sostener que no hay más verdad que la procesalmente declarada. Gascón Abellán (2010) señala que ambas desembocan en el mismo corolario inquietante: los jueces serían, por definición, infalibles (p. 40). Ese corolario resulta inadmisibile para cualquier teoría que aspire a controlar la decisión sobre los hechos, porque un juez infalible es un juez incontrolable.

Gascón Abellán formula la objeción con una precisión difícil de mejorar. La distinción entre esos dos conceptos, escribe, es posible e incluso necesaria si se quiere dar cuenta del carácter autorizado, pero falible, de la declaración de hechos de la sentencia (Gascón Abellán, 2010, p. 41). Que la decisión ponga fin a la

controversia no convierte en verdadero el enunciado que la sostiene. Mantener la distinción obliga a reconocer que la sentencia puede equivocarse. Cancelarla convierte el error judicial en una categoría conceptualmente imposible. La consecuencia práctica de esa cancelación es considerable. Un sistema que no puede pensar su propio error tampoco puede diseñar garantías contra él. Menos aún puede admitir que una parte demuestre haberlo padecido, que es precisamente lo que un recurso pretende. La falibilidad de la sentencia no es una concesión al escepticismo: es la condición de que exista algo que revisar.

La salida no consiste en elegir entre realismo ingenuo y escepticismo. Gascón Abellán (2010) sostiene que ese dilema es infundado y que existe, como poco, una tercera vía (p. 42). Esa vía adopta un paradigma epistemológico que toma en serio las tesis postpositivistas sobre la carga teórica de la observación, sin renunciar por ello a un cierto realismo. El juicio de hecho pasa entonces a concebirse como una elección entre reconstrucciones posibles de los hechos de la causa. Taruffo (2013) precisa el criterio de esa elección al exponer la regla de la probabilidad prevalente. Resulta racional escoger, respecto de un enunciado de hecho, la hipótesis confirmada en un nivel mayor al de la hipótesis contraria (p. 61). Cuando concurren varias hipótesis sobre el mismo hecho, el criterio racional consiste en elegir la que aparece sustentada por un grado de corroboración probatoria relativamente mayor al de todas las demás (Taruffo, 2013, p. 62). La fórmula anticipa con exactitud el estándar escalonado que se propone en el capítulo cuarto de este trabajo.

El realismo moderado tiene un rendimiento metodológico que conviene subrayar. La distinción entre verdad y prueba pone de manifiesto la necesidad de establecer garantías epistemológicas para que la declaración de hechos se aproxime lo más posible a la verdad (Gascón Abellán, 2010, p. 41). El protocolo de administración que se propone en el capítulo tercero pertenece íntegramente a esa categoría. No promete verdad, sino que reduce la probabilidad de error y hace visible el recorrido por el que se llegó a la conclusión. La simetría del argumento merece atención. Un tribunal que se declara infalible no necesita garantías epistemológicas, porque por hipótesis nunca yerra, y un tribunal que niega la posibilidad de conocer tampoco las necesita, porque no hay nada que garantizar. Solo el realismo moderado las vuelve exigibles, y por eso constituye el presupuesto de toda la propuesta.

1.1.3. *El modelo cognoscitivista exige enunciados fácticos verdaderos y controlables*

El realismo moderado se concreta en un modelo determinado de conocimiento judicial de hechos. Gascón Abellán (2010) lo formula en los siguientes términos:

El modelo epistemológico que vamos a adoptar es el cognoscitivista. Entendemos por tal aquel modelo según el cual los procedimientos de fijación de los hechos se dirigen a la formulación de enunciados fácticos que serán verdaderos si los hechos que describen han sucedido y falsos en caso contrario. (p. 49)

El concepto de verdad que el modelo requiere es el semántico de la correspondencia, y su principal criterio de verdad es la contrastación empírica (Gascón Abellán, 2010, p. 49). La fijación de los hechos no puede resultar, por tanto, del puro decisionismo ni del constructivismo. Debe ser el resultado de un juicio descriptivo sobre hechos a los que se atribuye existencia independiente del proceso. El modelo excluye así, desde el principio, la idea de que la verdad se construya en el tribunal. Esa exclusión tiene un precio y una ventaja. El precio consiste en admitir que la sentencia puede errar. La ventaja consiste en que ese error se vuelve alegable por las partes y revisable por el órgano superior, lo que sería imposible si la verdad se agotara en lo declarado.

Los dos adjetivos del modelo cargan con exigencias distintas. Que los enunciados sean fácticos significa que describen hechos acaecidos, de donde deriva una exigencia para el derecho sustantivo: la configuración legislativa del supuesto de hecho debe tener un referente empírico claro (Gascón Abellán, 2010, p. 49). Que los enunciados sean verdaderos plantea el problema principal, y la autora identifica tres razones por las cuales afirmarlo no es una cuestión trivial. El juez carece de acceso directo a los hechos y solo conoce enunciados sobre ellos, cuya verdad debe acreditarse. La verdad de tales enunciados se obtiene casi siempre por vía inductiva, a partir de otros enunciados fácticos. La averiguación se desarrolla, por último, a través de cauces institucionales que muchas veces estorban ese objetivo (Gascón Abellán, 2010, pp. 49-50). Las tres dificultades se acumulan en la prueba por indicios, que es la que ocupa a este trabajo.

De esas tres dificultades deriva la exigencia que atraviesa el presente trabajo, pues reforzar al máximo las garantías de verdad del proceso supone, al final, una exigencia de motivación (Gascón Abellán, 2010, p. 50). La primera dificultad resulta especialmente pertinente para la prueba indiciaria en materia electoral. El juzgador no presencié la entrega de propaganda ni la intervención de servidores públicos en

la jornada. Lo que tiene ante sí son enunciados sobre esos hechos, contenidos en documentos, imágenes y notas informativas de fiabilidad desigual. Acreditar la verdad de cada uno de esos enunciados, antes de relacionarlos entre sí, constituye el segundo paso del protocolo que se propone más adelante. La omisión de ese paso explica buena parte de los defectos que documenta el capítulo segundo. Un tribunal que no fija el hecho fuente carece de material sobre el cual razonar.

El modelo cumple dos funciones que conviene distinguir con cuidado. Como esquema teórico permite describir de manera simplificada realidades que en la práctica son complejas, y como parámetro permite medir esas mismas realidades desde el propio modelo (Gascón Abellán, 2010, p. 47). Gascón Abellán (2010) precisa que lo buscado es un modelo epistemológico teórico y útil (p. 48). Su utilidad consiste en examinar los procedimientos reales y en realizar una crítica epistémica sobre ellos. Esa crítica compara tales procedimientos con los principios derivados del modelo y propone la reforma de los aspectos que se separen de él. Esta investigación adopta la doble función sin alteraciones. El capítulo segundo describe una práctica jurisdiccional, y los capítulos tercero y cuarto la miden contra un modelo y formulan la propuesta correspondiente. Describir y proponer son operaciones distintas, y el trabajo las mantiene separadas para que la crítica no se confunda con el diagnóstico.

La autora acompaña el modelo de una advertencia que este trabajo asume como límite propio. Un modelo de descubrimiento no puede confundirse con el descubrimiento mismo, ni un modelo de justificación con la justificación. Confundirlos supone incurrir en la falacia normativista de quien toma el deber ser por el ser (Gascón Abellán, 2010, pp. 48-49). El riesgo consiste en presentar la práctica real «como si» transcurriera conforme al modelo, y un protocolo de valoración corre exactamente ese peligro. Puede degradarse hasta convertirse en una plantilla que legitime formalmente decisiones que no ejecutaron ninguno de sus pasos. El capítulo tercero atiende la objeción mediante una exigencia precisa: cada paso debe constar de manera verificable en el texto de la sentencia, y no basta con invocarlo en abstracto. La diferencia entre ejecutar un método y nombrarlo resulta central para el diagnóstico de este trabajo.

1.1.4. La epistemología jurídica opera en dos proyectos: describir las reglas y reformarlas

La disciplina que estudia estas cuestiones recibió un nombre y un programa precisos. Laudan (2013) sostiene que un sistema de justicia penal es primordialmente un motor epistémico (p. 23). Lo define como un dispositivo para descubrir la verdad a partir de lo que a menudo comienza con una mezcla confusa de pistas e indicios. El autor circunscribe la afirmación al proceso penal, pero la descripción conviene igualmente a la situación del juzgador electoral que examina un conjunto de pruebas imperfectas, ninguna de ellas concluyente por sí sola. Si el proceso es un motor epistémico, resulta pertinente preguntar si los procedimientos y reglas que lo estructuran conducen genuinamente a la averiguación de la verdad (Laudan, 2013, p. 23). Esa pregunta define la disciplina y ordena su programa de trabajo, que el autor delimita en dos proyectos:

De modo que la epistemología jurídica, concebida apropiadamente, consta de dos proyectos: a) uno de carácter descriptivo, consistente en determinar cuáles de las reglas vigentes promueven o facilitan la verdad y cuáles la obstaculizan, y b) otro normativo, consistente en proponer cambios en las reglas existentes al efecto de modificar o eliminar aquellas que constituyan impedimentos graves para la búsqueda de la verdad. (Laudan, 2013, p. 23)

Laudan (2013) advierte que la epistemología jurídica apenas existe como área reconocida de reflexión, pese a la aceptación casi universal de que el proceso busca averiguar la verdad (p. 23). El diagnóstico conserva vigencia en el derecho electoral mexicano, donde la discusión sobre la prueba se ha concentrado en la admisibilidad de los medios y en su valor tasado. La pregunta por la aptitud de las reglas para producir decisiones verdaderas ha recibido, en cambio, atención escasa. Este trabajo se sitúa precisamente en ese espacio vacante. No discute qué pruebas pueden ofrecerse ni cómo deben desahogarse, sino qué debe hacer el juzgador con las que ya obran en el expediente. El desplazamiento del objeto es deliberado, porque el problema diagnosticado no está en la entrada del material probatorio sino en su tratamiento posterior. La diferencia de objeto explica por qué la propuesta no requiere modificar el catálogo legal de medios probatorios, que permanece intacto en cuanto se refiere a su ofrecimiento y desahogo.

La estructura de esta tesis reproduce los dos proyectos con una diferencia relevante. El capítulo segundo desarrolla el proyecto descriptivo, al determinar cómo operó y cómo dejó de operar una regla vigente de valoración relacional. Los

capítulos tercero y cuarto desarrollan el proyecto normativo, aunque no de la manera que Laudan describe. La diferencia consiste en que aquí no se proponen cambios en las reglas existentes. Se propone explicitar el contenido de reglas que ya rigen, porque el diagnóstico no identifica una regla defectuosa sino una regla nunca desarrollada. La propuesta resulta por ello menos ambiciosa que la del autor citado, y gana a cambio una ventaja decisiva. Puede exigirse de inmediato, sin esperar a que ningún órgano legislativo la incorpore al derecho positivo ni a que se abra un ciclo de reforma.

Una precisión final delimita el alcance de este apartado. Gascón Abellán y Laudan construyen sus modelos con la mirada puesta en el proceso penal, y Laudan (2013) organiza el suyo alrededor de la distribución del error entre condenas falsas y absoluciones falsas (p. 22). Este trabajo no traslada ese régimen de garantías a la materia electoral, donde no rige la presunción de inocencia ni existe una asimetría equivalente entre los tipos de error. Toma de ambos autores algo distinto y más básico. Toma la tesis de que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento y admite, por tanto, criterios de corrección verificables. Esa tesis no depende de la materia en que se aplique. La justificación específica del traslado de categorías se desarrolla en el apartado 3.0.3, cuando el protocolo deba apoyarse en precedentes penales de la Suprema Corte.

1.2. La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso

El apartado anterior estableció que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento. Queda por determinar qué lugar ocupa ese conocimiento dentro del proceso, y la respuesta no es obvia. Buena parte de la teoría procesal contemporánea niega que la averiguación de la verdad sea una finalidad del proceso, o la subordina a la resolución del conflicto y a la legitimación social de la decisión. Este apartado sostiene la tesis contraria y precisa su alcance. La averiguación de la verdad no es un ideal externo que el proceso persigue cuando puede, sino la condición que permite al derecho funcionar. De esa tesis se siguen dos consecuencias que gobiernan el resto del trabajo. La prueba es el único instrumento epistémico admisible dentro del proceso. Y la verdad alcanzable resulta relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas disponibles, lo que la vuelve graduable y, por tanto, mensurable.

1.2.1. Sin averiguación de la verdad el derecho fracasa como mecanismo de dirección de conducta

Ferrer Beltrán (2007) aborda el problema desde las condiciones de éxito de la institución probatoria. Sostiene que para determinar los objetivos de una institución conviene establecer primero cuáles son esas condiciones (p. 29). El punto de partida es la función directiva del derecho. El legislador dicta normas para que sus destinatarios realicen o se abstengan de realizar determinadas conductas, y añade la amenaza de una sanción para quien no cumpla. Los sistemas jurídicos desarrollados prevén, por eso, órganos cuya función principal consiste en determinar la ocurrencia de los hechos a los que el derecho vincula consecuencias y en imponerlas a los sujetos previstos (Ferrer Beltrán, 2007, p. 29). La cadena completa depende de un eslabón fáctico. Si ese eslabón falla, fallan todos los que penden de él, por impecable que sea la técnica jurídica del resto de la resolución.

El autor prueba la tesis mediante un experimento mental. Supone que la sanción se atribuya aleatoriamente, de modo que los órganos de adjudicación sorteen cada mes quién debe ser sancionado y cuántas sanciones se impondrán (Ferrer Beltrán, 2007, p. 30). En ese escenario no existe vinculación alguna entre la conducta de cada miembro de la sociedad y la probabilidad de ser sancionado. Nadie tiene entonces razón para comportarse conforme a las normas jurídicas. El experimento aísla con nitidez lo que aporta la averiguación de la verdad: sin ella, la norma deja de motivar, porque su consecuencia se desprende de algo distinto de la conducta que la norma describe. La conclusión de Ferrer Beltrán (2007) es que la prueba tiene la función de comprobar la producción de los hechos condicionantes a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas (p. 30). El éxito de la institución probatoria se produce, en consecuencia, cuando las proposiciones sobre los hechos que se declaran probadas son verdaderas (Ferrer Beltrán, 2007, pp. 30-31).

La tesis admite un matiz que conviene incorporar desde ahora. Que la averiguación de la verdad sea el objetivo institucional de la prueba no significa que sea el único objetivo del proceso. Ferrer Beltrán (2007) advierte que afirmar la finalidad de una institución no excluye la existencia de otras finalidades o propósitos (p. 31). La regulación jurídica de la prueba impone, en muchos casos, excepciones a las reglas de la epistemología general. Esas excepciones protegen otros valores que comparten tutela jurídica con la averiguación de la verdad (Ferrer Beltrán, 2007, p. 31). El derecho electoral ofrece ejemplos inmediatos, empezando por los plazos perentorios que la definitividad de las etapas impone. La existencia de esas

excepciones no debilita la tesis: la refuerza, porque solo se concibe como excepción aquello que se aparta de una regla vigente.

1.2.2. La verdad de los hechos es condición necesaria, aunque no suficiente, de la justicia de la decisión

Taruffo (2013) formula la tesis en términos que no admiten equívoco. Sostiene que en el proceso los hechos determinan la interpretación y la aplicación del derecho, porque la averiguación de la verdad de los hechos es condición necesaria para la justicia de la decisión (p. 13). El argumento es sencillo y difícil de refutar. Ninguna decisión puede considerarse justa si se basa en una averiguación falsa o errónea de los hechos relevantes. La aplicación correcta de la norma presupone que haya ocurrido el hecho que ella misma identifica como condición (Taruffo, 2013, p. 13). El autor lo resume en una fórmula memorable: ninguna norma se aplica correctamente a hechos falsos o equivocados. La corrección jurídica de la sentencia depende, así, de la corrección de su base fáctica.

La afirmación admite una lectura desmedida que conviene descartar de entrada, y el propio Taruffo introduce la precisión. La averiguación de la verdad constituye solo una de las condiciones de justicia de la decisión, que además presupone un proceso desarrollado de manera correcta y legítima y una norma interpretada correctamente (Taruffo, 2013, p. 14). Se trata de una condición de por sí no suficiente, pero necesaria en todo caso. Que los hechos no se establezcan de manera verdadera basta para que la decisión sea injusta, aunque el proceso se haya desarrollado con toda corrección y la norma se haya interpretado con validez (Taruffo, 2013, p. 14). Ninguna de las tres condiciones es suficiente por separado, y las tres resultan necesarias en su conjunto. La distinción entre condición necesaria y condición suficiente sostiene todo el argumento. Quien la pasa por alto puede concluir, erróneamente, que basta con tramitar bien el proceso para decidir con justicia.

El autor identifica y descarta las principales objeciones a esa concepción. Menciona las filosofías que niegan la posibilidad de conocer la realidad externa al sujeto, entre ellas el relativismo radical según el cual cada quien tiene su verdad y nadie se equivoca (Taruffo, 2013, p. 14). Menciona también las concepciones que orientan el proceso solo a resolver controversias, de las que se sigue que la averiguación de la verdad no figura entre sus finalidades (Taruffo, 2013, p. 15). A los sostenedores de esas posiciones los denomina *veriphobics*, o enemigos de la

verdad, y observa que son muchos y de clases distintas (Taruffo, 2013, p. 15). Su crítica global es que, si a esas concepciones no les interesa el fundamento factual de la decisión judicial, entonces carecen de interés para quien se ocupa de cómo resolver litigios mediante decisiones justas (Taruffo, 2013, p. 16).

1.2.3. Las concepciones ritual y retórica de la prueba renuncian a la función epistémica

Dos concepciones merecen examen detenido, porque no niegan la verdad de manera frontal sino que la vuelven irrelevante. La primera es la concepción ritualista, que considera el proceso como un rito celebrado con ciertas modalidades, en lugares específicos y con sujetos vestidos de maneras extrañas (Taruffo, 2013, p. 81). Bajo esa mirada, el proceso opera como una representación teatral cuya función consiste en legitimar la decisión ante los ojos del público que presencia el rito. Lo que cuenta no es la calidad ni el contenido de la decisión, sino el procedimiento que concluye con ella. La prueba queda reducida a una parte del rito, y su función se vuelve retóricamente persuasiva hacia el público (Taruffo, 2013, p. 82). Sirve para hacer creer que la decisión final no fue arbitraria, no para establecer que no lo fue.

Taruffo (2013) extrae la consecuencia sin suavizarla. El procedimiento de creación y asunción de la prueba sirve, bajo esa concepción, para crear una apariencia, de un modo no distinto de lo que sucede en una representación teatral (p. 82). El fenómeno admite una lectura benévola, porque un teatro judicial que funciona bien produce consenso social sobre la administración de justicia. La objeción es que esa forma de pensar deja fuera el contenido y la calidad de la decisión. El autor lo enuncia con dureza: un rito eficaz puede legitimar cualquier decisión, incluso la condena de un inocente o la absolución de un culpable (Taruffo, 2013, p. 82). Basta con que el rito resulte eficaz para que la decisión sea aceptada. La aceptación social sustituye entonces a la corrección, y ninguna de las dos garantiza la otra.

La segunda concepción entiende el proceso como una competencia verbal entre narraciones que termina con la victoria del narrador más eficaz. La prueba se convierte allí en un instrumento de persuasión del que los abogados se sirven para convencer al juez o al jurado (Taruffo, 2013, pp. 82-83). Esta concepción tampoco es extraña ni marginal, pues resulta típica de quienes participan en el proceso con el fin de que su cliente venza. Taruffo (2013) objeta que también ella deja de lado el

contenido y la calidad de la decisión (p. 83). Ocurre con frecuencia que la victoria corresponde a la parte que desarrolló la mejor narración por ser retóricamente más eficaz, sin que esa narración tenga relación con la realidad de los hechos. La función de la prueba se vuelve entonces puramente retórica.

Estas dos concepciones interesan a la presente investigación por una razón que conviene adelantar. Ninguna de ellas exige que el juzgador valore el material probatorio, porque en ambas el resultado depende de algo distinto del conocimiento de los hechos. Una sentencia puede, por tanto, cumplir todas las formas del rito — admitir pruebas, celebrar la sesión, publicar la resolución— sin haber ejecutado en ningún momento la operación epistémica que la justifica. El capítulo segundo documenta una resolución con esas características, en la que el verbo valorar no aparece una sola vez. La distinción de Taruffo permite nombrar con precisión ese fenómeno. No se trata de una valoración defectuosa, sino de un proceso que operó como rito sin operar como instrumento de conocimiento. La diferencia importa, porque una valoración defectuosa se corrige mejorando el razonamiento y una valoración omitida no se corrige en absoluto.

1.2.4. La verdad procesal es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas

Frente a las concepciones anteriores, Taruffo sitúa la finalidad epistémica en el centro del proceso:

De esta forma se asigna al proceso una finalidad epistémica, ya que el descubrimiento de la verdad de las narraciones factuales se configura como una condición necesaria de la justicia de la decisión, y entonces también como un objetivo necesario del proceso. (Taruffo, 2013, p. 84)

La verdad así entendida no es absoluta. Taruffo (2013) precisa que en el proceso, como en cualquier experiencia humana incluida la ciencia, no se descubren verdades absolutas, de modo que la verdad procesal debe considerarse relativa (p. 84).

La relatividad requiere una lectura cuidadosa, y el autor la ofrece. No se trata de verdad relativa en el sentido del relativismo filosófico radical, según el cual cada sujeto tiene su propia verdad. Se trata de que la verdad se fundamenta en informaciones que permiten establecer si un enunciado es cierto, porque se apoya en datos que lo confirman (Taruffo, 2013, p. 84). La formulación decisiva llega enseguida: la verdad de los enunciados sobre los hechos del caso es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas en las que el juez basa su decisión (Taruffo,

2013, p. 84). La verdad opera entonces como un norte, esto es, como un ideal regulativo que orienta la actividad cognoscitiva (Taruffo, 2013, p. 85). Aunque ese norte nunca se alcance, resulta posible establecer cuánto se ha progresado en la dirección que marca.

Esa última idea suministra el fundamento conceptual del capítulo cuarto. Si la verdad procesal es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas, entonces el grado alcanzado es susceptible de medición y, por tanto, de enunciación. En el proceso puede establecerse, según las pruebas, en qué grado mayor o menor se ha acercado la decisión a la correspondencia entre los enunciados descriptivos y la realidad que describen (Taruffo, 2013, p. 85). Un estándar de suficiencia probatoria no hace otra cosa que fijar de antemano el grado exigible. La ausencia de estándar no elimina esa graduación, sino que la deja implícita y, con ello, sustraída al control de las partes. El problema que este trabajo aborda no consiste en que los tribunales gradúen, sino en que no digan cómo lo hacen.

La función epistémica de la prueba se articula, además, en dos dimensiones complementarias. La primera es heurística: la prueba sirve para descubrir qué ocurrió, pues antes de su adquisición solo caben ilaciones y narraciones hipotéticas (Taruffo, 2013, p. 85). La segunda es cognoscitiva o demostrativa, porque la prueba aporta los elementos que permiten reconocer el hecho y considerar verificada la verdad de los enunciados que lo describen (Taruffo, 2013, p. 86). De ambas dimensiones deriva una consecuencia que el capítulo tercero convierte en regla operativa. La prueba constituye un instrumento epistémico exclusivo, por ser la única manera posible de adquirir conocimiento de los hechos en el proceso. Resulta además indispensable adquirir todas las pruebas disponibles (Taruffo, 2013, p. 86). Un tribunal que ignora un elemento que consta en el expediente incumple esa exigencia.

El autor cierra el razonamiento con una precisión sobre el déficit probatorio. Cuando un hecho no resulta suficientemente probado, el juez no puede pronunciar un *non liquet* y debe decidir de todos modos. Habrá de hacerlo, entonces, aplicando la regla de juicio basada en la carga de la prueba, en lugar del conocimiento de los hechos (Taruffo, 2013, p. 86). La observación importa para el diagnóstico de este trabajo. Un tribunal que estima insuficiente el material probatorio dispone de una salida legítima y nombrable, que consiste en declararlo y resolver conforme a la carga de la prueba. Lo que no resulta admisible es omitir la valoración y, al mismo tiempo, omitir la invocación de esa regla de juicio. El capítulo segundo muestra que esa doble omisión es precisamente lo ocurrido en el caso de referencia.

1.3. La actividad probatoria se descompone en tres momentos

Las dos secciones anteriores establecieron que la fijación de los hechos es una operación de conocimiento y que el proceso persigue una finalidad epistémica. Falta descomponer esa operación en sus fases, porque el diagnóstico de esta tesis depende de distinguirlas. Ferrer Beltrán (2007) propone una descomposición en tres momentos que este trabajo adopta como armazón. La utilidad de la distinción es doble. Permite localizar con precisión en qué fase opera cada restricción jurídica, y permite advertir que la valoración, por sí sola, no decide nada. Esta última consecuencia resulta decisiva para el planteamiento del problema. Entre valorar y resolver media un estándar, y cuando ese estándar no se enuncia el tránsito queda sin control. El apartado reconstruye los tres momentos y muestra a cuál pertenece cada uno de los defectos que documenta el capítulo segundo.

1.3.1. La conformación del conjunto de elementos de juicio concentra las restricciones jurídicas

Ferrer Beltrán (2007) distingue tres momentos fundamentales en la toma de decisiones sobre hechos probados. Son la conformación del conjunto de elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión, la valoración de esos elementos y la adopción de la decisión propiamente dicha (p. 41). El autor advierte que se trata de tres momentos lógicamente distintos y sucesivos, aunque en los procesos reales puedan presentarse entrelazados (Ferrer Beltrán, 2007, p. 41). La advertencia importa. Que aparezcan entrelazados en la práctica no autoriza a confundirlos en el análisis, porque cada uno se rige por criterios distintos. Confundirlos produce, como se verá, errores que resultan invisibles mientras la distinción no se traza. El capítulo segundo muestra tres defectos superpuestos que solo se dejan nombrar por separado una vez que los momentos se distinguen.

El primer momento consiste en conformar, mediante la proposición y la práctica de las pruebas, un conjunto de elementos de juicio que apoyen o refuten las distintas hipótesis sobre los hechos del caso (Ferrer Beltrán, 2007, p. 41). Aquí aparece la especificidad jurídica de mayor calado. En los demás ámbitos del conocimiento el conjunto que puede analizarse coincide con el total de las informaciones disponibles y relevantes. En el derecho, en cambio, el conjunto de elementos a valorar es un subconjunto del formado por la totalidad de los elementos

disponibles: aquellos que han sido incorporados al expediente judicial (Ferrer Beltrán, 2007, p. 42). El juzgador no puede resolver con lo que sabe, sino con lo que consta. Esa restricción explica por qué el estudio de los filtros de admisión adquiere relevancia destacada. Lo que queda fuera del expediente queda fuera del razonamiento, por pertinente que sea.

El primer filtro es epistemológico y opera como principio general de inclusión. Una prueba es relevante si aporta apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los principios generales de la lógica y de la ciencia (Ferrer Beltrán, 2007, p. 42). A ese filtro inclusivo el derecho añade un número considerable de reglas de exclusión. Ferrer Beltrán (2007) señala que buena parte de ellas se justifican en la protección de valores distintos de la averiguación de la verdad (p. 43). Entre esas reglas figura una que el derecho electoral mexicano aplica con particular rigor. Los propios plazos procesales operan como regla de exclusión, de modo que queda fuera toda información aportada fuera de los plazos previstos, aunque sea relevante (Ferrer Beltrán, 2007, p. 43).

La correspondencia con la ley mexicana es exacta y conviene fijarla desde ahora. El artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece un catálogo tasado de medios admisibles, que funciona como regla de exclusión de los no enumerados. El artículo 16, párrafo 4, dispone que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, salvo la prueba superveniente. Ambos preceptos empobrecen deliberadamente el conjunto de elementos de juicio en nombre de la definitividad de las etapas del proceso electoral. La observación no es una crítica. Es la constatación de que el legislador ya decidió sacrificar riqueza epistémica en el primer momento, lo que vuelve más exigente el tratamiento del material que sí logró entrar.

Ferrer Beltrán (2007) formula una consecuencia que enlaza con el capítulo tercero de este trabajo. Sostiene que el control de racionalidad puede funcionar a posteriori bajo una condición. Debe exigirse al decisor que justifique por qué declaró probados esos hechos y cuál fue el apoyo empírico en el que basó su decisión (p. 44). Los sistemas que carecen de esa exigencia de motivación deben compensarla con reglas de exclusión abundantes, fijadas por anticipado. Los que sí la imponen pueden admitir más material y controlar después. El derecho electoral mexicano pertenece a este segundo grupo, porque los artículos 14 y 16 de la Constitución imponen fundar y motivar. De ahí se sigue que el control por vía de motivación no es

en este ordenamiento un complemento, sino el mecanismo principal de racionalidad.

1.3.2. La valoración es el momento de la racionalidad y su resultado es contextual

Cerrada la composición del conjunto, comienza el segundo momento. Ferrer Beltrán (2007) establece que, bajo un régimen de libre valoración, deberá valorarse el apoyo que cada elemento de juicio aporta a las hipótesis en conflicto, de forma individual y en conjunto (p. 45). La fórmula merece subrayarse porque contiene las dos operaciones que el artículo 16, párrafo 3, de la ley mexicana también exige. El resultado buscado consiste en saber el grado de confirmación del que dispone cada una de esas hipótesis (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). La valoración no produce, por tanto, un veredicto sobre la verdad. Produce una magnitud, que es el grado de apoyo conferido a cada hipótesis en competencia. Esa magnitud admite comparación, y sobre ella opera después el umbral. Confundir la magnitud con la conclusión es el primer paso hacia una decisión incontrolable.

El autor añade dos observaciones que este trabajo utiliza más adelante. La primera es que el resultado de la valoración es siempre contextual, esto es, referido a un determinado conjunto de elementos de juicio (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). Si el conjunto cambia por adición o sustracción de algún elemento, el resultado puede perfectamente ser otro. La consecuencia es de enorme importancia práctica. Omitir del conjunto un elemento que consta en el expediente no constituye un descuido menor, porque altera el resultado de toda la operación. Un tribunal que declara inexistente una prueba obrante en autos no comete un error de detalle. Valora un conjunto distinto del que tenía ante sí, y obtiene por ello un grado de confirmación que no corresponde al caso que resuelve. El vicio no está en la conclusión, sino en el conjunto sobre el que se razonó.

La segunda observación desmonta un equívoco extendido sobre la libre valoración. Ferrer Beltrán (2007) precisa que esa libertad existe solo en el sentido de que la valoración no está sujeta a normas jurídicas que predeterminen su resultado (p. 45). La operación de juzgar el apoyo empírico que un conjunto de elementos aporta a una hipótesis permanece sujeta a los criterios generales de la lógica y de la racionalidad (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). Libertad frente a la prueba tasada no equivale, en consecuencia, a libertad frente a la razón. El autor califica este segundo momento como el momento de la racionalidad. Sostiene que, una vez delimitado el

conjunto, la operación de valorar lo que de él puede inferirse no difiere de la que se realiza en cualquier otro ámbito de la experiencia (Ferrer Beltrán, 2007, p. 46).

De esa caracterización deriva un argumento que conviene retener para el capítulo segundo. Si en el momento de la valoración no rigen reglas jurídicas que predeterminen el resultado, entonces negar la posibilidad de decidir racionalmente en esa fase no puede fundarse en razones específicamente jurídicas. Ferrer Beltrán (2007) lo expresa señalando que tal negativa supone acoger argumentos escépticos generales sobre la posibilidad del conocimiento (p. 46). Las limitaciones propias del contexto jurídico —los plazos, los recursos, la intervención interesada de las partes— hacen que el conjunto disponible resulte epistemológicamente más pobre (Ferrer Beltrán, 2007, p. 46). Empobrecen el material, no la racionalidad de la operación que se practica sobre él. La distinción permite responder a quien alegue que las restricciones del proceso electoral impiden valorar con rigor. Las restricciones acotan el material; no autorizan a tratarlo con menor cuidado.

1.3.3. Sin estándar de prueba la valoración no determina decisión alguna

El tercer momento corresponde a la toma de la decisión, y es donde este trabajo localiza el vacío que pretende llenar. La valoración habrá permitido otorgar a cada hipótesis en conflicto un determinado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza absoluta (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). Resta decidir si la hipótesis puede declararse probada con el grado de confirmación de que dispone, y eso depende del estándar de prueba que se utilice (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). La elección de uno u otro estándar es propiamente jurídica y se realiza en atención a los valores en juego en cada tipo de proceso (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). La epistemología suministra el grado y el derecho fija el umbral. Ninguna de las dos disciplinas puede suplir a la otra en esa división de tareas.

El autor enuncia entonces la tesis que sostiene todo el planteamiento del presente trabajo:

Conviene insistir en que el resultado de la valoración de la prueba que se obtenga en el segundo momento no implica por sí solo nada respecto de la decisión a adoptar. Para ello, es necesaria la intermediación de algún estándar de prueba. Y ni siquiera puede darse por descontado que la hipótesis que haya resultado más confirmada es aquella que deberá darse por probada. (Ferrer Beltrán, 2007, p. 48)

La afirmación tiene consecuencias que conviene desplegar. Entre la valoración y la decisión media una operación distinta de ambas. Consiste en

contrastar el grado obtenido con una medida previamente fijada, y sin ella el tránsito de la una a la otra carece de justificación. La valoración informa la decisión, pero no la produce.

Esa operación intermedia no desaparece cuando el ordenamiento omite regularla. Un tribunal que declara probado o no probado un hecho ha aplicado necesariamente algún umbral, porque de otro modo no habría podido pasar del grado a la conclusión. La diferencia entre un sistema con estándar explícito y uno sin él no radica en que el segundo prescinda del umbral. Radica en que lo aplica sin declararlo, y por ello sin exponerlo a discusión. El material puede haber alcanzado un grado alto de confirmación y ser declarado insuficiente, o alcanzar uno bajo y ser declarado bastante, sin que ninguna de las dos decisiones resulte controlable. La arbitrariedad no consiste aquí en decidir mal, sino en decidir sin que nadie pueda verificar contra qué se decidió. La objeción alcanza por igual a las resoluciones que anulan y a las que confirman.

La última observación de Ferrer Beltrán en este punto refuerza el argumento desde un ángulo inesperado. El autor advierte que ni siquiera cabe presumir que la hipótesis más confirmada sea la que deba tenerse por probada (2007, p. 48). El estándar penal de la duda razonable ilustra esa posibilidad. Supone que la hipótesis de la culpabilidad no se tendrá por probada aunque cuente con más apoyo empírico que la de la inocencia, salvo corroboración muy alta (Ferrer Beltrán, 2007, p. 48). El umbral puede, en consecuencia, invertir el resultado de la valoración, y no solo confirmarlo. Un sistema que lo mantiene tácito deja esa inversión fuera de todo escrutinio. Quien no lo enuncia se reserva un poder considerable, porque conserva la facultad de fijarlo después de conocer el grado alcanzado. Esa facultad es justamente la que un estándar explícito suprime.

1.3.4. La distinción de los tres momentos ordena el protocolo y el umbral

La descomposición en tres momentos organiza los dos entregables de esta tesis y conviene dejar explícita la correspondencia. Los dos primeros pasos del protocolo que se propone en el capítulo tercero —el inventario del material indiciario y la acreditación autónoma de cada fuente— pertenecen al primer momento, el de la conformación del conjunto. Los pasos tercero a quinto —la explicitación de la máxima de experiencia, la adminiculación relacional y la contrastación con hipótesis rivales— pertenecen al segundo, el de la valoración. El sexto paso y el estándar escalonado del capítulo cuarto pertenecen al tercero, el de la decisión. La

correspondencia no es decorativa. Cada momento se rige por criterios distintos, de modo que un instrumento diseñado para uno no sirve para otro. Exigir motivación donde falta prueba, o reclamar pruebas donde falta umbral, son errores de diagnóstico antes que de solución.

La distinción permite también precisar el diagnóstico del capítulo segundo. Cuando un tribunal declara que determinados elementos solo constituyen un indicio y que no se aportaron otros, comete errores que pertenecen al primer momento, porque describe mal el conjunto disponible. Cuando omite relacionarlos entre sí, el error pertenece al segundo. Y cuando concluye que el material no basta sin decir cuánto habría bastado, el error pertenece al tercero. Los tres defectos suelen presentarse juntos y confundidos bajo una misma fórmula de rechazo. Separarlos es la condición para nombrarlos, y nombrarlos es la condición para corregirlos. El protocolo del capítulo tercero y el estándar del cuarto operan, por eso, sobre momentos distintos y no son intercambiables entre sí.

1.4. La inferencia probatoria tiene una estructura identificable

Los apartados anteriores fijaron que la decisión sobre los hechos es cognoscitiva, que persigue la verdad y que se descompone en tres momentos. Queda por examinar la operación que ocupa el segundo de esos momentos. González Lagier (2005) se propone reconstruir el tipo de razonamiento por medio del cual se prueban los hechos de un caso, y llama a ese razonamiento inferencia probatoria (p. 53). La reconstrucción interesa a este trabajo por una razón práctica. Una operación cuya estructura puede describirse admite un control que la mera invocación de la sana crítica no permite. Este apartado identifica los elementos de esa estructura. Muestra después que cada uno de ellos genera una exigencia de explicitación distinta, y que esas exigencias se convierten en pasos del protocolo del capítulo tercero. La estructura no determina el resultado de ninguna valoración concreta, pero fija qué debe aparecer en una sentencia para que la valoración pueda discutirse.

1.4.1. La prueba se descompone en dos fases y la segunda encadena inferencias

González Lagier (2005) distingue, a efectos analíticos, dos fases dentro de la ambigua palabra prueba. La primera consiste en la práctica de las pruebas y en la obtención de información a partir de ellas, esto es, a partir de lo que dicen los

testigos, los documentos y los peritos (pp. 53-54). La segunda consiste en extraer una conclusión a partir de la información obtenida en la primera (González Lagier, 2005, p. 54). La primera fase establece las premisas del argumento que trata de probar una hipótesis, y la segunda realiza la inferencia que permite pasar de esas premisas a la conclusión. La distinción coincide con la que el apartado anterior tomó de Ferrer Beltrán, aunque González Lagier la traza dentro del razonamiento y no dentro del procedimiento. Las dos reconstrucciones convergen en lo esencial. Obtener información y extraer de ella una conclusión son operaciones distintas, y confundirlas lleva a tratar como dato lo que ya es resultado de un razonamiento.

El razonamiento de la segunda fase rara vez consta de un solo paso. El autor advierte que puede ser muy complejo y constar de un encadenamiento de argumentos o inferencias parciales (González Lagier, 2005, p. 54). En el extremo inicial de la cadena figura la información obtenida directamente de las pruebas practicadas, y en el extremo final una hipótesis sobre lo ocurrido. Entre ambos extremos se sitúan premisas y conclusiones intermedias, cada una de las cuales resulta de una inferencia previa. La consecuencia metodológica es considerable. Controlar una inferencia probatoria no consiste en examinar un salto único. Consiste en examinar cada eslabón de una cadena que puede ser larga. Un eslabón defectuoso compromete todo lo que pende de él, por sólido que sea el resto del razonamiento.

El autor ilustra el punto con un ejemplo que conviene reproducir por su precisión. Un policía declara que se encontró en la vivienda de Ticio un arma del mismo calibre que la que causó la muerte de Cayo. González Lagier (2005) observa que la información obtenida directamente es que el policía declara que el arma fue encontrada, no que realmente el arma fuera encontrada (p. 54). Lo segundo ya es el resultado de la valoración de la fiabilidad de tal declaración, esto es, el resultado de un razonamiento y de una inferencia (González Lagier, 2005, p. 54). La observación parece obvia y no lo es. Entre el documento y el hecho media siempre una inferencia que suele quedar tácita. Esa inferencia tácita es la que el paso segundo del protocolo obliga a exteriorizar. Cuando un tribunal afirma que un acordeón impreso acredita la existencia de una estrategia de distribución, o cuando niega que la acredite, está resolviendo esa inferencia sin enunciarla.

1.4.2. *Cuatro elementos componen toda inferencia probatoria*

González Lagier reconstruye la inferencia probatoria con un esquema argumentativo de cuatro elementos, que atribuye a Toulmin. La pretensión es aquello que se sostiene y las razones son los datos que la apoyan. La garantía explica por qué esas razones apoyan esa pretensión, y el respaldo muestra la corrección o vigencia de la garantía. El autor precisa que la garantía consiste siempre en una regla, norma o enunciado general (González Lagier, 2005, p. 56). Los dos primeros elementos son particulares del caso y los dos últimos son generales. La distinción explica por qué unos se acreditan con pruebas y otros con argumentos. Añade que los cuatro elementos deben estar presentes en toda argumentación, sea jurídica, científica o de la vida cotidiana (González Lagier, 2005, p. 56). La generalidad del esquema es lo que permite trasladarlo sin forzarlo a un ámbito determinado.

El traslado al razonamiento judicial sobre hechos resulta directo. Los hechos probatorios constituyen las razones del argumento, y los hechos a probar, la pretensión o hipótesis del caso (González Lagier, 2005, p. 57). La garantía queda constituida por las máximas de experiencia, las presunciones y otros enunciados generales. Esos enunciados correlacionan el tipo de hechos señalado en las razones con el señalado en la pretensión. El respaldo queda configurado, por su parte, por la información necesaria para fundamentar la garantía (González Lagier, 2005, p. 57). La inferencia probatoria se deja describir, en consecuencia, como el paso de unos hechos probatorios a unos hechos a probar mediante una garantía apoyada en un respaldo. La descripción es sencilla, y por eso resulta utilizable como rejilla de lectura de cualquier sentencia. Basta preguntar, ante cada conclusión fáctica, cuáles fueron las razones, cuál la garantía y cuál el respaldo.

Esa descripción tiene un rendimiento inmediato para el control de la decisión. Cada uno de los cuatro elementos puede faltar, y la falta de cada uno produce un vicio distinto. Si faltan las razones, no hay material sobre el cual razonar. Si falta la garantía, el paso de las razones a la pretensión queda sin justificar y solo cabe aceptarlo por autoridad. Si falta el respaldo, la garantía se afirma sin fundamento y puede ser una generalización arbitraria. Y si la pretensión no se enuncia con precisión, no se sabe qué se está probando ni, por tanto, cuándo quedaría probado. Un protocolo de valoración que exija exteriorizar los cuatro elementos permite localizar cuál de ellos falló, en lugar de descalificar el razonamiento en bloque.

La Suprema Corte llegó por su cuenta a una exigencia equivalente, aunque con otro vocabulario. Al fijar los requisitos de la inferencia lógica en la prueba indiciaria, estableció que de los hechos base acreditados debe fluir la conclusión como consecuencia natural, con enlace directo entre unos y otra (Tesis 2004755, 2013). El enlace del que habla la Corte es la garantía del esquema. Añadió también que, cuando los mismos hechos probados permiten arribar a diversas conclusiones, el juzgador debe tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima conveniente (Tesis 2004755, 2013). Esa segunda exigencia no pertenece a la estructura de la inferencia, sino a su contraste con hipótesis rivales, y se examina en el apartado siguiente. Doctrina y jurisprudencia convergen, en todo caso, sobre el mismo punto: el enlace debe mostrarse, no suponerse.

La jurisprudencia electoral mexicana ofrece un ejemplo poco advertido de garantía explícita. La Jurisprudencia 38/2002 no se limita a afirmar que las notas periodísticas arrojan indicios. Enuncia la regla general que gradúa su fuerza. Cuando se aportan varias notas provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y además no obra mentís del afectado, cabe otorgarles mayor calidad indiciaria. El criterio hace visible aquello que suele quedar tácito, porque enuncia la correlación entre el tipo de hecho probatorio y el tipo de hecho a probar. Es, en los términos del esquema, una garantía formulada por el propio tribunal. El capítulo segundo examina por qué ese modelo, ya disponible desde 2002, no se aplicó al material periodístico del caso de referencia.

1.4.3. La garantía admite tres fuentes y solo dos de ellas son probatorias

González Lagier (2005) desagrega la garantía en tres clases (p. 61). La primera son las máximas de experiencia, que el autor subdivide a su vez. Pueden ser de carácter científico o especializado, como las que aportan los peritos, o de carácter jurídico, como las derivadas del ejercicio profesional del juez. Pueden ser también de carácter privado, derivadas de las experiencias del juzgador al margen de su profesión. La segunda clase son las presunciones, que se establecen legal o jurisprudencialmente. La tercera son las definiciones o teorías, que suelen provenir de la doctrina, aunque también de la jurisprudencia o de la ley. La clasificación importa porque el respaldo exigible difiere en cada caso. Una máxima científica se respalda con el dictamen pericial; una presunción jurisprudencial, con el precedente

que la estableció; y una experiencia corriente, solo con la observación de casos anteriores.

La tercera clase merece una advertencia que el autor formula de inmediato. Cuando la unión entre los hechos probatorios y el hecho a probar viene dada por una teoría o una definición, el vínculo es conceptual. En ese supuesto no estamos en sentido estricto ante un caso de prueba, sino ante uno de interpretación o calificación de los hechos (González Lagier, 2005, p. 61). La distinción resulta especialmente pertinente en materia electoral. Determinar si unos hechos acreditados constituyen coacción del voto, o si una irregularidad merece el calificativo de grave, no es una operación probatoria sino calificatoria. Confundir ambas permite presentar como insuficiencia de prueba lo que en realidad es un desacuerdo sobre la calificación. Ese desplazamiento resulta difícil de detectar cuando la garantía no se explicita, porque el lector no puede saber si el tribunal discute los hechos o su encuadre jurídico.

Las máximas de experiencia de carácter privado plantean el problema inverso y más frecuente. Al proceder de la experiencia corriente del juzgador, tienden a operar sin enunciarse, porque quien las emplea las considera evidentes. El artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral remite de forma expresa a la experiencia como criterio de valoración. No exige, en cambio, que la máxima empleada se declare. Esa remisión sin carga de explicitación es una de las puertas por las que entra la discrecionalidad no controlable. Una máxima enunciada puede discutirse y refutarse. Una máxima tácita solo puede intuirse a partir del resultado, de modo que la parte que quiera combatirla debe adivinarla primero.

1.4.4. Explicitar la estructura es lo que vuelve criticable la inferencia

Dos observaciones adicionales del autor completan el cuadro y afectan de manera directa al diseño del protocolo. La primera es que los hechos probatorios admiten grados de interpretación, según se sitúen más cerca de lo meramente percibido o incorporen el sentido que se atribuye a lo percibido (González Lagier, 2005, p. 60). El autor añade una regla de tendencia: cuanto más se avanza en la cadena de razonamientos, más interpretados resultan los hechos probatorios (González Lagier, 2005, p. 60). El material que sirve de base a los últimos eslabones no tiene, por tanto, la misma calidad epistémica que el de los primeros. Tratar todos los hechos probatorios como equivalentes ignora esa degradación progresiva, y

conduce a exigir lo mismo a un hecho percibido directamente que a uno reconstruido tras varios eslabones.

La segunda observación es que los hechos probatorios pueden ser a su vez el resultado de otra inferencia del mismo tipo (González Lagier, 2005, p. 60). La prueba consiste entonces en el encadenamiento de varias inferencias sustancialmente análogas, y cada una de ellas reproduce la estructura de cuatro elementos. La consecuencia converge con lo que la Suprema Corte estableció al fijar los alcances de la prueba indiciaria. La eficacia de la prueba circunstancial disminuye en la medida en que las conclusiones deban obtenerse a través de mayores inferencias y cadenas de silogismos (Tesis 2004753, 2013). Doctrina y jurisprudencia coinciden, así, en que la longitud de la cadena degrada el apoyo. La coincidencia es valiosa para el capítulo tercero, porque permite anclar una exigencia epistemológica en un criterio vigente del propio sistema mexicano. El protocolo no importa una doctrina extranjera: recoge lo que la Suprema Corte ya resolvió.

De ese conjunto se sigue la tesis del apartado. Una inferencia probatoria cuya estructura permanece implícita no puede criticarse, porque no se sabe qué se está criticando. Quien impugna una valoración sin conocer la máxima de experiencia aplicada solo puede oponer su propia conclusión a la del tribunal, y el desacuerdo se vuelve irresoluble. Exteriorizar los cuatro elementos no obliga al juzgador a decidir de un modo determinado. Le obliga a mostrar el recorrido, que es cosa distinta y mucho más modesta. El paso tercero del protocolo recoge precisamente esa exigencia. La limita, además, a lo que el artículo 16, párrafo 1, ya presupone cuando remite a la lógica, la sana crítica y la experiencia. No se pide al juzgador nada que la ley no dé por supuesto. Se le pide que lo escriba, que es la única forma de que un tercero pueda comprobarlo.

1.5. La solidez de la inferencia admite criterios de control

El apartado anterior mostró que la inferencia probatoria tiene una estructura descriptible. Describirla no basta, sin embargo, para controlarla, porque hace falta saber cuándo una inferencia resulta sólida y cuándo no lo es. Ese es el problema del que se ocupa este apartado. González Lagier (2005) ofrece una respuesta articulada en once criterios, ordenados según el elemento de la estructura al que se refieren. Este trabajo los adopta porque cumplen la condición que el objetivo general exige: son verificables desde fuera de la sentencia. Su enunciación permite, además, algo que el capítulo cuarto necesitará. Si la solidez admite grados,

entonces admite medida, y lo que admite medida admite umbral. El apartado recorre los once criterios agrupados en tres bloques y cierra con la consecuencia que de todos ellos se sigue.

1.5.1. La remisión a la sana crítica es vaga y puede precisarse

González Lagier (2005) parte de una constatación que el derecho electoral mexicano confirma. La doctrina procesal y la jurisprudencia superaron ya la lectura de la libre valoración como íntima convicción. Sostienen ahora que la valoración no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino una actividad sujeta a pautas (González Lagier, 2005, p. 79). Debe someterse, en cambio, a las reglas de la lógica, a las de la sana crítica, a las de la experiencia, al criterio racional o al criterio humano (González Lagier, 2005, p. 79). El autor añade entonces la objeción decisiva. Se trata de referencias sumamente vagas y muy difíciles de concretar (González Lagier, 2005, p. 79). El diagnóstico recae sobre fórmulas idénticas a las que emplea la ley mexicana, lo que convierte la objeción en algo más que una discusión doctrinal ajena.

La coincidencia literal merece subrayarse. El artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena valorar atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Son exactamente las tres fórmulas que González Lagier califica de sumamente vagas, de modo que el precepto mexicano no incurre en un defecto local sino que reproduce el estado general de la cuestión. La consecuencia importa para el planteamiento de este trabajo. La crítica que aquí se dirige a la práctica del Tribunal Electoral no le imputa haber inventado una imprecisión. Le imputa no haberla resuelto pese a disponer de los materiales para hacerlo, y haber tolerado durante casi tres décadas que la remisión legal operara en blanco, sin que ninguna resolución la dotara de contenido verificable.

El autor sostiene que esa vaguedad puede reducirse. Cabe dar criterios más concretos, o precisar qué son las reglas de la sana crítica, tomando algunas pautas de racionalidad epistemológica elaboradas para justificar las inducciones científicas (González Lagier, 2005, p. 80). La propuesta no elimina la vaguedad por completo, y el propio autor advierte que los criterios conservan un grado elevado de imprecisión. Reducirla representa, con todo, una ganancia considerable para quien deba impugnar una valoración ajena. Un criterio impreciso pero enunciado puede discutirse. Una remisión en blanco no admite discusión, porque no ofrece nada

sobre lo que discrepar. Los once criterios que siguen se ordenan según se refieran a los hechos probatorios, a la garantía o a la hipótesis del caso, que son los tres elementos de la estructura fijada en el apartado anterior.

1.5.2. Cuatro criterios controlan los hechos probatorios

El primer criterio interroga la fiabilidad. González Lagier (2005) señala que la fiabilidad depende de cómo se haya llegado a conocer los hechos probatorios (p. 81). Distingue tres vías de conocimiento: la observación directa del juez, las conclusiones científicas y el resultado de otra inferencia. Las dos primeras ofrecen mayor fiabilidad, pero en la mayor parte de los supuestos los hechos probatorios son conclusiones de otras inferencias previas. Que un testigo diga que oyó discutir a dos personas solo prueba de forma directa que el testigo lo dijo (González Lagier, 2005, pp. 81-82). Lo mismo sucede con un documento, pues habrá que inferir que su contenido es cierto (González Lagier, 2005, p. 82). La declaración y el documento acreditan de forma inmediata su propia existencia, no la del hecho que refieren.

El autor extrae de ahí dos consecuencias operativas. La primera es que esas inferencias intermedias, a las que rara vez se presta atención, son inevitables, y cada una puede ser un punto débil de la argumentación en su conjunto (González Lagier, 2005, p. 82). La segunda es una regla de graduación: la fiabilidad de los hechos probatorios es mayor cuanto menor es la cadena de inferencias que lleva hasta ellos (González Lagier, 2005, p. 82). El autor añade una observación que desactiva una distinción muy arraigada. En sentido estricto, la única prueba directa es la observación inmediata por el juez (González Lagier, 2005, p. 82). Todo lo demás resulta mediato en algún grado, de modo que la oposición entre prueba directa e indirecta describe una diferencia de grado y no de naturaleza.

El segundo criterio interroga la suficiencia. Cuantos más hechos apunten en dirección a la hipótesis, mayor será la seguridad sobre su corrección. González Lagier (2005) matiza de inmediato ese criterio aritmético. Un solo hecho probatorio con alto grado de fiabilidad puede tener un peso mayor que varios hechos probatorios de escasa fiabilidad (p. 82). La suficiencia no se resuelve, por tanto, contando elementos, y la precisión resulta especialmente pertinente para el derecho electoral, donde la exigencia de pluralidad probatoria suele formularse en términos numéricos. Contar pruebas y ponderarlas son operaciones distintas, y solo la segunda constituye valoración. Un tribunal que reprocha al promovente no haber

aportado más elementos, sin examinar antes la fiabilidad de los que sí aportó, se detiene en la primera de esas dos operaciones y omite la segunda.

El tercer criterio interroga la variedad, y es el más relevante para esta investigación. El autor sostiene que la variedad de los hechos probatorios aumenta la probabilidad de la hipótesis que confirman (González Lagier, 2005, p. 83). Su importancia radica en que permite la eliminación de las hipótesis alternativas con las que la principal entra en competencia (González Lagier, 2005, p. 83). El ejemplo que ofrece el autor traslada bien al terreno electoral. Si los hechos contra un acusado de tráfico de droga se reducen a las acusaciones de vecinos con quienes mantiene pésimas relaciones, cabe pensar que la causa sea la animadversión. Esa hipótesis alternativa se debilita al encontrarse una balanza de precisión. Se debilita todavía más al hallarse en la balanza restos de cocaína (González Lagier, 2005, p. 84). Cada elemento nuevo cierra una vía de escape distinta.

El ejemplo suministra el fundamento epistemológico de la adminiculación. Lo que derrota a la hipótesis alternativa no es la acumulación de elementos del mismo tipo, sino la aparición de elementos de tipo distinto. Tres acusaciones más de los mismos vecinos no habrían debilitado en absoluto la explicación por animadversión, mientras que la balanza sí lo hace. El artículo 16, párrafo 3, al ordenar considerar los demás elementos que obren en el expediente, presupone exactamente esa lógica. La adminiculación no es una suma de valores probatorios, sino un procedimiento de eliminación de explicaciones rivales. El capítulo tercero recoge esa idea en el paso cuarto del protocolo. La diferencia entre sumar y eliminar explica por qué un conjunto heterogéneo puede sostener aquello que ninguno de sus elementos sostiene por separado, y por qué la homogeneidad del material debilita la inferencia aunque aumente su volumen.

El cuarto criterio interroga la pertinencia. No todos los hechos sirven para confirmar una hipótesis, sino solo los que guardan relación con el hecho descrito en ella. González Lagier (2005) precisa que un hecho no será pertinente cuando no esté correlacionado con la hipótesis ni por presunciones ni por máximas de experiencia adecuadas y bien fundadas (p. 85). El criterio remite, por tanto, a la corrección de la garantía, con lo que cierra el círculo abierto en el apartado anterior. Sin garantía enunciada no puede determinarse la pertinencia de un elemento. Declarar impertinente una prueba sin explicitar la máxima aplicada produce, por eso, una decisión que no admite control, porque el afectado no llega a saber qué correlación se consideró inexistente ni puede, en consecuencia, combatirla.

1.5.3. *Dos criterios controlan la garantía*

El primer criterio pregunta si la garantía está suficientemente fundada. González Lagier (2005) recuerda que las máximas de experiencia son a su vez la conclusión de una inducción ampliativa, por lo que no son necesariamente verdaderas sino probables (p. 86). Su credibilidad racional depende de que esa inducción esté bien hecha, de modo que hay que examinar el fundamento cognoscitivo de las máximas y regularidades empleadas. Solo así se excluyen las generalizaciones apresuradas y los prejuicios (González Lagier, 2005, p. 86). El autor añade una exigencia complementaria. No basta con que la máxima aplicada esté bien fundada. Debe además no haber máximas mejor fundadas que desautoricen el paso de los hechos probatorios a la hipótesis (González Lagier, 2005, p. 86). La exigencia obliga a considerar las regularidades que juegan en contra, y no solo las que favorecen la conclusión adoptada.

El criterio se acompaña de una advertencia sobre las reglas construidas para la ocasión. Si la regla se elaboró para explicar el caso concreto que el juez debe decidir, entonces no se basa en una inducción ampliativa bien fundada (González Lagier, 2005, p. 87). La máxima construida a la medida del caso resulta inservible, porque carece de la generalidad que es justamente lo que convierte a un enunciado en garantía. El autor precisa también el estatuto de las presunciones. Pueden verse como máximas de experiencia institucionalizadas y autoritativas, y en esa medida deben apoyarse igualmente en una inducción sólida (González Lagier, 2005, p. 87). Una presunción jurisprudencial no queda exenta de fundamento por el hecho de provenir de un tribunal, aunque su carácter autoritativo limite el margen del juzgador para desplazarla.

El segundo criterio pregunta por el grado de probabilidad causal que la garantía establece. Existen máximas que correlacionan dos fenómenos con alta probabilidad y máximas que establecen esa correlación con una probabilidad sensiblemente menor. González Lagier (2005) formula la regla correspondiente: cuanto menor sea el grado de probabilidad causal expresado por la máxima de experiencia, menor será la probabilidad inferencial con la que se sigue la hipótesis final (pp. 87-88). La regla tiene aplicación inmediata en materia electoral. Afirmar que quien aparece en un impreso de propaganda obtuvo por ello más votos supone una máxima de probabilidad causal baja, y la conclusión hereda esa debilidad. Enunciar esa máxima obliga a reconocer el límite de la inferencia. Omitirla permite

presentar como fuerte un razonamiento que no lo es, y el vicio opera en las dos direcciones: también permite descartar por débil lo que la máxima sostendría.

1.5.4. Cinco criterios controlan la hipótesis

El primer criterio pregunta si la hipótesis ha sido refutada. González Lagier (2005) distingue dos formas de refutación (p. 88). Una hipótesis queda refutada de manera directa cuando su verdad resulta incompatible con otra afirmación que se ha dado por probada, y de manera indirecta cuando implica una afirmación que se demuestra falsa o poco probable. La exigencia opera con independencia del apoyo que la hipótesis haya recibido de los hechos probatorios, de modo que la confirmación no dispensa de comprobar la ausencia de refutación. Aunque los hechos probatorios la confirmen, todavía debe someterse al requisito de la no refutación. Confirmación y ausencia de refutación son condiciones distintas, y la segunda no se sigue de la primera. Una hipótesis muy apoyada puede quedar destruida por un solo hecho incompatible con ella.

El segundo criterio pregunta si se han confirmado las hipótesis derivadas. Esas hipótesis refutan la principal cuando se demuestran falsas, y aumentan su credibilidad cuando se confirman como verdaderas (González Lagier, 2005, p. 90). El tercer criterio, y el más exigente, pregunta si se han eliminado las hipótesis alternativas. Cuando pueden eliminarse todas las que compiten por explicar un hecho, salvo una, esa debe tomarse como verdadera (González Lagier, 2005, p. 90). El autor advierte de inmediato que se trata de un ideal rara vez alcanzable en un proceso judicial. Lo usual es disponer de varias hipótesis y escoger la que resiste mejor los intentos de refutación (González Lagier, 2005, p. 90). La exigencia realista no consiste en la eliminación total de las alternativas, sino en la comparación razonada entre aquellas que subsisten tras el examen.

De ese tercer criterio deriva una regla que el capítulo cuarto retomará. La credibilidad de una hipótesis disminuye cuantas más hipótesis alternativas subsistan (González Lagier, 2005, pp. 90-91). La formulación convierte la refutación en un factor de graduación y no en un requisito binario, de manera que no se trata de eliminar toda alternativa concebible sino de reducir el número de las que siguen en pie. La Suprema Corte alcanzó una conclusión equivalente al exigir que el juzgador tenga en cuenta todas las conclusiones posibles y razone por qué elige la que estima conveniente (Tesis 2004755, 2013). Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la elección entre hipótesis debe justificarse y no simplemente declararse. La

convergencia permite exigir ese razonamiento con apoyo en criterio vigente del sistema mexicano, y no únicamente en doctrina extranjera, lo que resulta decisivo para la viabilidad de la propuesta.

Los dos criterios restantes operan como reglas de desempate. El cuarto es la coherencia, que presenta un aspecto interno de congruencia entre los enunciados que integran la hipótesis y otro externo de congruencia con el resto del conocimiento disponible (González Lagier, 2005, p. 91). El quinto es la simplicidad, según el cual las hipótesis más simples son las que explican más con un menor número de presuposiciones (González Lagier, 2005, p. 91). El autor señala que ambos criterios sirven únicamente para escoger entre hipótesis que cuentan con un grado de confirmación semejante. Su función es, por tanto, subsidiaria. Ninguno de los dos suple la falta de apoyo empírico, de modo que una hipótesis coherente y simple pero desprovista de confirmación sigue siendo una conjetura, por elegante que resulte su formulación.

1.5.5. La solidez es gradual y esa graduación es la que un estándar debe medir

La advertencia con que González Lagier introduce los criterios resulta tan importante como los criterios mismos. La solidez de la inferencia probatoria es gradual en dos sentidos distintos (González Lagier, 2005, p. 80). En una inferencia dada pueden estar presentes más o menos criterios, y la ausencia de alguno no constituye por sí sola razón para rechazarla. Casi todos los criterios pueden cumplirse, además, en mayor o menor medida (González Lagier, 2005, p. 80). La doble gradualidad impide convertir los once criterios en una lista de requisitos cuya falta invalide la inferencia. Los criterios describen un espectro y no un umbral, de manera que confundirlos llevaría a un formalismo tan rígido como el sistema de prueba tasada que la libre valoración vino a superar.

Esa advertencia condiciona el diseño del protocolo del capítulo tercero. Un protocolo construido sobre estos criterios no puede funcionar como una lista de comprobación cuyo incumplimiento anule la valoración. Debe funcionar como una rejilla que obligue a exteriorizar cada operación y a declarar en qué grado queda satisfecha, y la diferencia entre una cosa y otra resulta sustancial. Una lista de requisitos sustituiría la libre valoración por una prueba tasada de nuevo cuño, que es precisamente lo que este trabajo no propone. Una rejilla de exteriorización deja intacta la libertad valorativa y suprime únicamente su opacidad. El juzgador

conserva íntegra la facultad de apreciar el material probatorio, y pierde únicamente la de no explicar cómo lo apreció.

La gradualidad suministra, por último, el puente hacia el capítulo cuarto. Si la solidez de una inferencia admite grados, entonces cabe preguntar qué grado resulta exigible para tener un hecho por probado. Esa segunda pregunta ya no pertenece a la epistemología sino al derecho, conforme a la distinción entre valoración y decisión que el apartado 1.3 tomó de Ferrer Beltrán. Los criterios de González Lagier permiten decir cuán sólida es una inferencia. No permiten decir cuán sólida debe ser, porque esa medida depende de los valores en juego en cada tipo de proceso. El estándar escalonado que se propone más adelante responde a esa segunda pregunta. Presupone resuelta la primera, y por eso el capítulo tercero debe preceder al cuarto en el orden de la exposición: no cabe fijar cuánto basta antes de haber fijado cómo se mide.

1.6. El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos

Los apartados anteriores examinaron la inferencia probatoria como operación individual. Queda por resolver una cuestión distinta y decisiva para esta investigación. El artículo 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena atender a los demás elementos que obren en el expediente. Ordena también atender a la relación que esos elementos guardan entre sí, y ese segundo mandato presupone que el conjunto aporta algo que sus elementos aislados no aportan. Este apartado examina el fundamento de ese presupuesto y, sobre todo, sus límites. La conclusión anticipa el diseño del capítulo tercero. El conjunto importa, aunque no de la manera que el holismo narrativo sugiere, y precisar esa diferencia resulta indispensable para que la propuesta resista la objeción más seria que puede dirigírsele.

1.6.1. Tres objeciones al tratamiento aislado de los elementos de prueba

Amaya (2015) reconstruye el debate entre atomismo y holismo en la teoría de la prueba y recoge tres objeciones dirigidas contra el primero (pp. 94-95). La primera sostiene que la prueba de todo caso controvertido se compone de elementos pertenecientes al menos a dos relatos contradictorios, uno falso y otro verdadero, que aparecen entremezclados. Solo al adoptar la decisión final cabe identificar cuáles de esos elementos pertenecen al relato verdadero y cuáles al falso. De ahí

que resulte ilógico asignar un valor de verdad o de probabilidad a un elemento aislado antes de la decisión, que es precisamente lo que el atomismo exige (Amaya, 2015, p. 94). La objeción apunta a un problema de orden. El atomismo pretende resolver al principio lo que solo puede resolverse al final, cuando ya se conoce a qué relato pertenece cada pieza.

La segunda objeción resulta la más pertinente para el derecho electoral mexicano. En la medida en que los elementos de prueba están enlazados entre sí formando un todo conectado, ningún elemento debe tratarse de manera aislada respecto de los demás, contra lo que el atomismo requiere (Amaya, 2015, pp. 94-95). La formulación describe con exactitud la operación que el artículo 16, párrafo 3, ordena cuando manda atender al recto raciocinio de la relación que los elementos guardan entre sí. La tercera objeción sostiene que el enfoque atomista socava el carácter fáctico de la prueba judicial. Lo hace al convertir los hechos en proposiciones inferidas de la experiencia general, con lo que desatiende indebidamente las circunstancias del caso concreto (Amaya, 2015, p. 95). Las tres objeciones convergen en un mismo reproche. Tratar cada elemento por separado destruye información que solo existe en la relación entre ellos.

De ese diagnóstico deriva una tesis positiva que interesa retener. Conforme a la versión del holismo que Amaya expone, no cabe extraer conclusiones fácticas a partir de elementos de prueba aislados, por notables que resulten. El juzgador debe ponderar la prueba y alcanzar una conclusión solo después de haber examinado el conjunto del material del caso (Amaya, 2015, p. 95). El enunciado tiene consecuencias prácticas inmediatas para el control de las sentencias. Declarar que un elemento no acredita nada por sí solo es compatible con que el conjunto al que pertenece sí acredite algo. Confundir ambas afirmaciones es el error que el capítulo segundo documenta en el caso de referencia, cuando la sentencia sostiene que los elementos aportados solo constituyen un indicio. El singular de esa fórmula delata la operación: dos pruebas de origen distinto quedan reducidas a una sola unidad de valoración, y con ello desaparece la relación que las une.

1.6.2. El derecho mexicano recogió la objeción holista desde 1974

La objeción no es ajena a la tradición jurídica mexicana, ni reciente en ella. La Suprema Corte la formuló con notable economía hace más de medio siglo. Estableció que la prueba indiciaria resulta de la apreciación en su conjunto de los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, y que esos elementos no

deben considerarse aisladamente (Tesis 235868, 1974). Añadió que de su armonía lógica, natural y concatenamiento legal habrá de establecerse una verdad resultante, que conduzca de manera unívoca e inequívoca a la verdad buscada (Tesis 235868, 1974). La coincidencia con el planteamiento holista es notable, sobre todo por la distancia temporal y disciplinar que separa ambas formulaciones. Una tesis aislada de la Séptima Época y la teoría contemporánea de la prueba coinciden en rechazar el tratamiento fragmentario del material probatorio. El criterio mexicano no requiere, por tanto, actualización doctrinal: requiere aplicación.

La jurisprudencia electoral llegó al mismo punto por su propia vía. La Jurisprudencia 19/2008 sostiene que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente. De ese carácter unitario deriva que la fuerza convictiva de los medios de prueba deba valorarse en relación con las pretensiones de todas las partes, y no solo del oferente. El criterio se enunció bajo el rótulo de la adquisición procesal, pero su alcance excede esa figura. Afirma que el expediente constituye una unidad, que es exactamente la premisa que la segunda objeción al atomismo defiende. El sistema mexicano dispone, por tanto, de dos anclajes propios para exigir la valoración conjunta. A ellos se suma la Jurisprudencia 4/2014, que impone adminicular la prueba técnica con otro elemento que la perfeccione o corrobore, con lo que presupone que la relación entre elementos produce un valor del que carecen por separado.

1.6.3. El holismo narrativo es peligroso y no puede fundar el protocolo

La exposición anterior quedaría incompleta y sería tendenciosa si omitiera las objeciones que el holismo ha recibido. Amaya (2015) las recoge con detalle, y este trabajo las asume en lugar de esquivarlas. La primera sostiene que las teorías coherentistas están seriamente subdesarrolladas, y que conceptos clave como plausibilidad y coherencia se emplean de manera imprecisa. La consecuencia es grave: las teorías holistas no proporcionan un criterio claro para escoger entre explicaciones alternativas de los hechos en competencia (Amaya, 2015, p. 125). Una teoría que no ofrece criterio de elección resulta inservible como fundamento de un protocolo, porque el protocolo necesita precisamente eso. La objeción no es menor ni externa: proviene, según recoge Amaya, de autores simpatizantes del propio holismo.

La segunda objeción advierte sobre los riesgos del enfoque que considera el caso como un todo. Los relatos pueden emplearse para introducir de contrabando consideraciones irrelevantes y para desviar la atención de las debilidades del argumento. Sirven también para apelar a la emoción antes que a la razón y para recurrir a prejuicios o estereotipos ocultos (Amaya, 2015, p. 125). La conclusión que Amaya recoge resume el problema con precisión: los relatos son sin duda necesarios, pero peligrosos. El riesgo tiene traducción electoral evidente. Una narración coherente sobre una elección irregular puede resultar persuasiva sin que ninguno de sus elementos esté acreditado. Lo mismo cabe decir de la narración contraria, que presenta el proceso como impecable apoyándose en la sola regularidad formal de sus etapas. El peligro opera, por tanto, en ambas direcciones.

Taruffo figura entre quienes formulan esa advertencia, y conviene registrarlo porque su obra integra el corpus de este trabajo. Amaya (2015) recoge que el autor previene contra los peligros de adoptar un enfoque holista, porque sugiere decidir con base en algo distinto de las pruebas (p. 125). Las teorías holistas desatenderían así problemas como la definición del hecho, la relevancia de la prueba y la carga probatoria. En su propia obra Taruffo (2013) resulta todavía más tajante. Considera inatendible y desviante la perspectiva holística propuesta por algunos exponentes del narrativismo judicial (p. 59). La objeción no admite despacho rápido, y obliga a precisar con cuidado qué se toma del holismo y qué se deja fuera. Una tesis que ignorase esa advertencia quedaría expuesta a la réplica más obvia.

1.6.4. La pregunta correcta es por el dominio de cada modelo

La salida de la disyuntiva la ofrece, dentro de la propia exposición de Amaya, el enfoque conciliador de Tillers. Su propósito no consiste tanto en defender una versión del holismo como en reconciliar holismo y atomismo. Ninguno de los dos permite ofrecer un retrato fiel del razonamiento sobre hechos en el derecho (Amaya, 2015, p. 95). El enfoque atomista pasa por alto que el significado de la prueba se adhiere a veces al conjunto del material. Tanto el análisis atomista como las apreciaciones holistas desempeñan, en consecuencia, un papel importante en la inferencia jurídica (Amaya, 2015, p. 96). Ningún modelo por sí solo describe la inferencia jurídica de manera completa, de modo que un retrato de la inferencia racional exige recurrir a varias teorías de la prueba lógicamente dispares (Amaya, 2015, p. 96).

De ahí se sigue el desplazamiento de la pregunta que este trabajo adopta. La cuestión correcta no consiste en determinar si un modelo de inferencia es o no correcto, sino en determinar cuál es el dominio propio de cada uno (Amaya, 2015, p. 97). Formulada así, la disputa entre atomismo y holismo deja de ser una elección entre doctrinas rivales. Se convierte en un problema de asignación, consistente en determinar qué operación corresponde a cada fase del razonamiento probatorio. La reformulación permite conservar lo que el holismo aporta sin incurrir en los riesgos que sus críticos denuncian. Permite, además, no contradecir a quienes lo rechazan como método único de decisión, porque la objeción de esos autores recae sobre un uso del holismo que aquí tampoco se defiende.

La reconciliación se confirma al examinar lo que el propio Taruffo exige. Pese a rechazar la perspectiva holística, sostiene que debe establecerse el grado de confirmación que cada prueba atribuye al enunciado. A partir de ahí ha de determinarse el grado global o de conjunto de corroboración que ese enunciado recibe de todas las pruebas que lo atañen (Taruffo, 2013, p. 59). La exigencia de un grado de conjunto es, sin más, una exigencia de valoración relacional, por mucho que el autor la formule desde una perspectiva analítica. Lo que Taruffo rechaza no es atender al conjunto, sino sustituir el examen de cada elemento por la impresión global de coherencia narrativa. Su posición y la segunda objeción al atomismo resultan, así, compatibles entre sí, y ambas sostienen el mandato del artículo 16, párrafo 3.

De esa compatibilidad deriva la regla que gobernará el paso cuarto del protocolo. La administración que este trabajo propone es una agregación analítica y no una apreciación narrativa. Exige valorar primero cada elemento y determinar después el grado de corroboración que el conjunto confiere a la hipótesis. La secuencia responde a la fórmula que Ferrer Beltrán expresa al exigir la valoración individual y en conjunto. No autoriza a sustituir el examen de los elementos por la elección del relato más convincente. Con esa delimitación, el mandato del artículo 16, párrafo 3, queda a salvo de la objeción de Taruffo. Conserva además el fundamento epistemológico que le suministra la eliminación de hipótesis alternativas, examinada en el apartado anterior. El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos porque cierra vías de escape, no porque componga un relato más agradable.

1.7. Libre convicción como principio metodológico negativo; la sana crítica no es criterio

Los apartados anteriores reconstruyeron la estructura de la inferencia probatoria y sus criterios de solidez. Queda por resolver una cuestión previa a esa construcción y que ha generado más confusión doctrinal de la que merece. Tanto la Suprema Corte como la jurisprudencia electoral mexicana remiten a la «libre convicción» y a la «sana crítica» como fundamentos de la valoración. Ambas expresiones sugieren, a primera vista, que el juzgador goza de discreción amplia para decidir conforme a su conciencia. Este apartado examina qué significa realmente cada una de esas expresiones, cuál es el alcance legítimo de esa discreción y por qué la confusión entre el significado originario y sus usos posteriores ha generado un problema de controlabilidad de las sentencias. La conclusión anticipada es que la «libre convicción» es un principio metodológico negativo —rechaza el apriorismo legal— pero no un criterio positivo de valoración, y que la «sana crítica» nunca fue un criterio sustantivo sino una referencia a máximas de experiencia.

1.7.1. Principio negativo versus criterio positivo de valoración

La distinción entre uno y otro es fundamental y ha quedado opacada por el uso indiferenciado de ambas expresiones. Gascón (2005) la traza con precisión al examinar la historia de la libre convicción en el derecho procesal. El rechazo de la prueba legal fue un giro revolucionario. La prueba legal predeterminaba el valor de cada medio mediante reglas abstracción: el testigo presenciador, la confesión espontánea, el documento público, cada uno tenía un peso fijo establecido por la ley. De ahí que Ferrajoli (1995) hablase de esa época como de una de las «páginas políticas más amargas e intelectualmente más deprimentes de la historia de las instituciones penales». La libre convicción fue la reacción contra ese sistema fetichista. Su propósito consiste simplemente en «el rechazo de las pruebas legales como suficientes para determinar la decisión» (Gascón, 2005, p. 142). Con esa precisión, la libre convicción no es un criterio positivo que diga cómo debe valorarse, sino un principio *negativo* que deshace el camino contrario: prescribe que el juzgador *no* está sujeto a tasaciones previas.

La diferencia tiene consecuencias prácticas decisivas. Un principio negativo deja sin resolver la cuestión de cómo proceder una vez rechazado el apriorismo legal. Una vez que la ley no fija el valor de la prueba, el juzgador debe determinar

ese valor mediante algún método. La libre convicción marca dónde no se puede estar —bajo la coacción de reglas legales— pero no marca dónde se debe estar. Por eso Gascón afirma que «la libre valoración no puede interpretarse más que en su significado primigenio: un *principio metodológico (negativo)*. Pero un principio metodológico y sólo eso. No, por tanto, un *criterio (positivo)* de valoración» (Gascón, 2005, p. 142). La línea que separa ambas cosas es la que separa lo permitido de lo prescrito: la libre convicción permite al juzgador desligarse de reglas aprióricas; no prescribe cómo decidir sin ellas. Confundir ambas cosas convierte un límite al formalismo en autorización para la arbitrariedad.

1.7.2. *La desviación histórica: de principio a subjetividad descontrolada*

El uso posterior de la libre convicción se apartó de ese significado originario. En lugar de entenderse como rechazo del apriorismo legal, pasó a interpretarse como «valoración libre, sin sujeción a reglas de ningún tipo» (Gascón, 2005, p. 142). Con ese cambio de significado, la libre convicción dejó de ser una garantía epistemológica y se convirtió en una puerta abierta a la subjetividad descontrolada. El juzgador recibía el encargo de «decidir según su conciencia» o según su «íntima convicción», pero sin instrucción acerca de cómo formar esa convicción racionalmente. Nieva Fenoll (2015) describe el problema con economía. Una vez rechazadas las reglas de la prueba legal, el juez «se deja solo, a fin de que haga lo que haya de hacer a su libre albedrío, lo que significa que su juicio estarán muchas veces imperfecto, o difícilmente motivable por estar con frecuencia basado en intuiciones derivadas de una experiencia no siempre bien aprehendida, a falta de otros datos en que apoyarse» (Nieva Fenoll, 2015, p. 90). La observación apunta al mismo problema que la distinción de Gascón: en ausencia de criterios positivos, el juzgador no queda liberado sino desorientado.

Lo que ocurrió en la jurisprudencia penal angloamericana es instructivo. Laudan (2005) registra que a través del siglo XX, la «duda razonable» —que en su origen significó una medida epistémica precisa relacionada con la epistemología de Locke— fue deliberada y lentamente desplumada hasta quedar reducida a «un 'careces de toda duda', esto es, a tener una alta confianza subjetiva» (Laudan, 2005, p. 99). La forma jurídica se mantuvo, pero el contenido se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue precisamente lo que la libre convicción no era en su origen: la convicción íntima del juzgador, inaprensible, incomunicable, imposible de verificar. El problema es que «bajo tales estándares» la convicción se vuelve parasitaria de su propia

base: el jurado debe determinar si la culpabilidad se ha probado, pero sin regla que le diga cuándo ha alcanzado esa convicción (Laudan, 2005, p. 106). En esas circunstancias, la «libre convicción» deja de ser una garantía y se convierte en un problema.

1.7.3. La sana crítica no es un criterio sino una referencia a máximas de experiencia

La «sana crítica» ocurre algo parecido, aunque su historia es distinta. La expresión, que remite a la «buena conciencia» medieval, aparece en fuentes españolas desde el siglo XIX como alternativa discreta al lenguaje de la «libre convicción». Nieva Fenoll (2015) examina su evolución y concluye que nunca fue un criterio sustantivo sino una referencia poco precisa a máximas de experiencia. El art. 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 disponía que los jueces valorarían las declaraciones testificales «según las reglas de la sana crítica». Pero, como Nieva observa, esa referencia «no aporta mucho en toda esta materia» (Nieva Fenoll, 2015, p. 88), porque no especifica qué reglas son las de la «sana crítica» ni cómo aplicarlas.

El problema no es que la expresión sea incorrecta sino que es demasiado vaga. Nieva Fenoll señala que «De Vicente y Caravantes valoró la referencia legal a la sana crítica como una obligación del juez de apreciar, además de otras máximas de experiencia sociológicas, las facultades psicológicas de los testigos» (Nieva Fenoll, 2015, p. 89). La sana crítica se entendía, entonces, como la aplicación de máximas de experiencia psicológicas y sociológicas a la valoración de la prueba. Eso es todo cuanto fue, y es todo cuanto puede ser. No proporciona un método, ni siquiera una orientación clara. Solo apunta en la dirección correcta: que el juzgador use el juicio para aplicar máximas de experiencia. Pero eso no es lo que ha llegado a significar en la práctica, donde la «sana crítica» se ha convertido en un sinónimo vagamente tranquilizador de «el juez decide como considera conveniente». La realidad es que la doctrina española fue más consciente del problema de lo que la práctica posterior sugiere. Nieva Fenoll recoge que la doctrina española de los siglos XVII-XIX «fue bien consciente de este problema, aunque con motivaciones que ensobrecieron la etología del problema y, por tanto, su solución» (Nieva Fenoll, 2015, p. 89), porque temían que un criterio estricto menguase la autoridad del juez.

1.7.4. *Un estándar subjetivo no es un estándar*

La confusión entre principio negativo y criterio positivo encuentra su expresión más clara en la pretensión de que la «convicción íntima» o la «confianza subjetiva» pueden funcionar como estándar de prueba. Laudan (2005) dedica su artículo precisamente a demostrar que no pueden. Un estándar de prueba, para serlo, debe cumplir una función precisa: proporcionar al juzgador una regla que le permita saber cuándo ha alcanzado suficiente certeza para decidir. Eso presupone una medida, algo que pueda comunicarse, verificarse y discutirse. La «íntima convicción» no es ninguna de esas cosas.

Laudan parte de una observación sobre los estándares penales angloamericanos. Oficialmente, el estándar es «más allá de una duda razonable», que sugiere una medida epistémica. Pero en la práctica, muchos jueces y juristas lo han reinterpretado como «la confianza subjetiva que cada juez sienta», transformando un criterio en la negación de un criterio (Laudan, 2005, p. 99). El resultado es problemático. Si el estándar es «la convicción íntima de cada juez», entonces dos jueces enfrentados a la misma evidencia pueden aplicar el mismo estándar y llegar a conclusiones opuestas. El ejemplo que Laudan construye es particularmente claro: si un juez asigna una probabilidad de 90% a la culpabilidad y otro la asigna de 95%, y ambos declaran que tienen «confianza» en esa estimación, ¿cuál de ellos aplicó el estándar correctamente? «Si el estándar en ese lugar es el BARD, la pregunta se reduce a esto: ¿estás completamente persuadido de que él lo cometió? Si, por el contrario, han sido abogados académicos los que han impuesto su forma de entender el estándar y han establecido que éste es del 90%, la pregunta que debes hacerte será: ¿tu evaluación de la probabilidad de culpabilidad es mayor del 90%?» (Laudan, 2005, p. 104).

Laudan destaca que confundir la subjetividad de la convicción inicial del juez con la verificabilidad del estándar produce una consecuencia indeseable: «en realidad, las frases construidas por la doctrina alemana en nada se diferencian de los estándares de prueba anglosajonas. No orientan a jurados, sino a jueces y finalmente, eso es exactamente la misma» (Nieva Fenoll, 2015, p. 92). La conclusión es incómoda pero inevitable. Si todos los jueces dicen que tienen «convicción» pero no especifican en qué consiste, entonces no hay estándar verificable de que todos apliquen el mismo criterio. La apariencia de uniformidad oculta divergencias imposibles de detectar.

1.7.5. La exigencia de explicitación como condición de controlabilidad

El problema que plantean la libre convicción vaga y la sana crítica indeterminada es un problema de controlabilidad. Una valoración que no puede describirse no puede discutirse, y una sentencia que no expone la valoración que realiza deja al lector sin forma de verificar si la decisión resultó de la aplicación de criterios o de pura arbitrariedad. Por eso el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no se limita a remitir a la «libre convicción» sino que conjuga tres estándares: «reglas de la lógica, sana crítica y experiencia». Ese triple anclaje importa, porque no es lo mismo remitir a uno solo.

La lógica proporciona criterios verificables: una conclusión que contradice sus premisas es lógicamente falsa, y eso puede demostrarse. Las máximas de experiencia pueden enunciarse y discutirse, aunque su aplicación en el caso concreto admita debates. La experiencia del juzgador, finalmente, es un factor inevitable pero debe quedar supeditada a los dos primeros. El problema comienza cuando cualquiera de estos tres se interpreta como sinónimo de «convicción íntima» y queda entonces exonerado de justificación.

De ahí que el protocolo del capítulo tercero insista en la explicitación. No se trata de obligar al juzgador a decidir de un modo determinado ni de negarle su experiencia y su juicio. Se trata de hacer que lo escriba, de exigir que comunique qué regla lógica aplicó, cuál fue la máxima de experiencia y por qué la consideró aplicable, cuál fue el peso que confirió a su propia experiencia en relación con las pruebas que contradicen esa experiencia. La libre convicción, como principio negativo, seguirá siendo tan libre como siempre. Pero dejará de ser convicción íntima para convertirse en convicción justificada, y eso —solo eso— es lo que la hace compatible con el Estado de Derecho.

1.8. Un estándar subjetivo no es un estándar

El recorrido de los apartados anteriores deja una pregunta pendiente. Si la libre convicción es un principio negativo que rechaza la tasación legal, y si la sana crítica nunca fue un criterio sustantivo, ¿qué queda? La respuesta usual es que queda la «convicción íntima» o la «confianza subjetiva» del juzgador. Este apartado examina por qué esa respuesta no resuelve el problema: una convicción subjetiva no puede funcionar como estándar de prueba, porque le falta precisamente lo que todo

estándar debe tener. La conclusión tiene consecuencias prácticas decisivas para la controlabilidad de la decisión.

1.8.1. Qué requiere un estándar de prueba para serlo

Laudan (2005) comienza por lo elemental. Un estándar de prueba, para cumplir su función, debe proporcionar al juzgador una regla que le permita determinar cuándo ha alcanzado la certeza suficiente para decidir. Esa exigencia presupone tres cosas: una medida, algo que pueda comunicarse y algo que pueda verificarse (Laudan, 2005, p. 95). La «íntima convicción» carece de las tres. No es una medida porque la convicción personal es privada y variable de un juez a otro. No puede comunicarse porque consiste en un estado emocional o cognitivo interno que cada persona experimenta de forma distinta. Y no puede verificarse porque no hay criterio externo que permita a un tercero saber si la convicción de un juez es genuina, o si alcanza el nivel que el sistema presupone (Laudan, 2005, pp. 95).

Frente a esa carencia, un estándar verdadero debe ser capaz de cumplir dos operaciones. La primera consiste en guiar al juzgador durante el proceso de deliberación, indicándole cuándo ha reunido prueba suficiente. La segunda consiste en permitir que terceros —las partes, los órganos de apelación, la opinión pública— verifiquen que el juzgador aplicó el estándar correctamente. Una convicción subjetiva no satisface ninguna de las dos. No puede guiar porque no existe instrucción que defina qué es una «convicción», ni cuándo se alcanza, ni cómo se distingue de un mero presentimiento. Y no puede verificarse porque el resultado —la sentencia que declara al acusado culpable o inocente— es el único dato disponible, y ese dato no revela si la convicción que la motiva es auténtica o si basta para justificar la decisión (Laudan, 2005, p. 95).

1.8.2. La corrupción histórica de la duda razonable

El problema no es teórico. Laudan (2005) documenta cómo la historia del derecho procesal penal anglo-estadounidense registra precisamente ese proceso de degradación. El estándar oficial es la «duda razonable» (BARD). En su origen, esa expresión significaba una medida epistemológica precisa, relacionada con la epistemología de Locke y el cálculo de probabilidades (Laudan, 2005, p. 99). Pero a lo largo del siglo XX, especialmente durante el derecho estadounidense moderno, la «duda razonable» fue deliberada y lentamente desplumada de su contenido

epistemológico. A través de diversas reinterpretaciones jurisprudenciales, llegó a significar simplemente «tener una alta confianza subjetiva acerca de la culpabilidad» (Laudan, 2005, p. 99). La forma jurídica se mantuvo —los jueces siguen pronunciando las palabras «más allá de una duda razonable»—, pero el contenido se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue precisamente lo que el apartado anterior examinó: la convicción íntima del juzgador.

La consecuencia es que el estándar se convirtió en parasitario de su propia base: el jurado debe determinar si la culpabilidad se ha probado, pero sin regla que le diga cuándo ha alcanzado esa convicción (Laudan, 2005, p. 106). En esas circunstancias, como el autor observa, «hoy en día, el punto de vista oficial de la Corte Suprema es que una condición necesaria y suficiente para condenar al acusado en un juicio penal es una creencia firme de la culpabilidad por parte del jurado» (Laudan, 2005, p. 99). Pero esa creencia nunca se especifica. Los jueces y juristas académicos no reciben instrucción sobre qué significa «creencia firme», ni sobre cómo distinguirla de una creencia débil, ni sobre cuál es el umbral que la separa de la duda.

1.8.3. Dos vías convencionales y sus defectos comunes

Laudan (2005) examina dos intentos históricos de definir un estándar de prueba en el derecho penal, uno cualitativo y otro cuantitativo. El primer camino, que llama «duda razonable» (BARD), requiere que el juzgador tenga una «certeza moral» o «convicción que va más allá de la duda razonable» de que el acusado cometió el delito (Laudan, 2005, p. 98). El segundo camino, de corte académico- bayesiano, propone en su lugar un nivel de probabilidad (generalmente entre el 90% y el 95%) que debe alcanzarse antes de condenar (Laudan, 2005, p. 98).

Ninguno de los dos es satisfactorio. En el BARD, la dificultad radica en que la noción de «certeza moral» o «convicción» es ella misma subjetiva. Cuando Laudan pregunta qué significa que un jurado esté «completamente persuadido», la respuesta que recibe es que depende de la creencia privada de cada jurado. Así, dos jurados pueden estar igualmente seguros de la culpabilidad —uno asignando una probabilidad de 90%, otro de 95%— y ambos pueden declarar que tienen «confianza» en esa estimación. Pero ¿cuál de ellos aplicó el estándar correctamente? Si el estándar es BARD, la pregunta se reduce a esto: «¿estás completamente persuadido de que él lo cometió?» Si, por el contrario, han sido abogados académicos quienes han establecido que el estándar es del 90%, la

pregunta que debe hacerse es: «¿tu evaluación de la probabilidad de culpabilidad es mayor del 90%?» (Laudan, 2005, p. 104). Las dos preguntas son radicalmente distintas, y la respuesta depende de cuál sea la que se plantee.

El camino cuantitativo, por su parte, tropieza con un obstáculo diferente. Incluso si se estableciera de forma explícita que el estándar es una probabilidad de 95%, esa precisión no elimina la subjetividad de la estimación inicial. Laudan (2005) ilustra el punto con un ejemplo constructor. Si un juez comienza un caso asignando una probabilidad previa de inocencia de 95%, y después examina la evidencia, llega a una estimación final de probabilidad de culpabilidad. Pero esa estimación final depende de sus creencias iniciales —lo que él cree que es «probable»— acerca de si el acusado es culpable o inocente. Si otro juez comienza el mismo caso con una presunción de inocencia de 50% —es decir, con una creencia inicial completamente neutral—, su estimación final será más alta. En ambos casos, el resultado dependerá «entre otras cosas, de las creencias subjetivas iniciales del jurado acerca de la culpabilidad e inocencia» (Laudan, 2005, p. 101). La precisión numérica oculta una multiplicidad de creencias subjetivas que operan bajo la superficie.

1.8.4. El problema de la uniformidad

El defecto fundamental que afecta a ambas vías es que hacen que el estándar dependa de datos que no pueden uniformarse. Laudan (2005) lo expresa así: en un sistema donde el estándar de prueba es la «convicción subjetiva del juzgador respecto de la culpabilidad», la determinación de cuándo se ha satisfecho el estándar «dependerá inevitablemente, entre otras cosas, de las creencias subjetivas iniciales del jurado acerca de la culpabilidad o inocencia» (Laudan, 2005, p. 101). Eso significa que dos jueces enfrentados a exactamente la misma evidencia pueden aplicar lo que creen es el mismo estándar y llegar a conclusiones completamente opuestas, sin que exista criterio alguno para resolver el desacuerdo.

El autor agrega una observación sobre lo que esto implica para el sistema. Si múltiples jueces dicen que tienen «convicción» pero no especifican en qué consiste, entonces «no hay distinción» entre los estándares como hasta aquí considerados (Laudan, 2005, p. 92), que derivó en que los estándares de prueba «no orientan a jurados, sino a jueces y finalmente, eso es exactamente la misma» (p. 92). La conclusión es incómoda pero inexorable: si todos los jueces declaran tener «convicción» pero nunca tienen que explicar en qué consiste esa convicción,

entonces no existe estándar verificable que todos apliquen. La apariencia de uniformidad oculta divergencias imposibles de detectar.

1.8.5. La función de un estándar en la distribución del error

Hay un nivel más profundo en el que la subjetividad incapacita al estándar. Laudan (2005) sostenía que el único mecanismo para distribuir errores en favor del acusado es un estándar no-subjetivo de la prueba. Si situamos ese estándar en la altura correcta, capturará completamente nuestras creencias compartidas acerca de la razón apropiada de absoluciones falsas a condenas falsas (Laudan, 2005, p. 112). Una regla de prueba que funciona verdaderamente cumple una tarea de ingeniería social: especifica de antemano cuál es la proporción de errores que la sociedad está dispuesta a tolerar y luego vincula el comportamiento del juez a esa proporción.

Pero eso solo es posible si el estándar es independiente de la psicología individual del juez. Cuando el estándar es «la convicción íntima» o «la confianza subjetiva», el sistema renuncia a esa capacidad. En su lugar, lo que queda es un estándar parasitario del nivel de confianza que el investigador (esto es, el jurado) tenga respecto de la culpabilidad del acusado (Laudan, 2005, p. 106). No hay forma de saber de antemano cuál será el resultado, porque depende de datos que no pueden controlarse: las creencias privadas de cada juez acerca de lo que es «probable» o «seguro».

1.8.6. La conclusión operativa

Laudan (2005) cierra su argumento con una conclusión que resulta directamente aplicable al problema mexicano. Si el estándar de prueba fuese formulado en términos de una probabilidad específica —digamos el 90% o el 95%—, sería casi seguro que muchos de los jurados que han decidido que el acusado cometió el delito estarían en apuros para determinar, de una manera que no sea meramente arbitraria, si su confianza en la culpabilidad satisfizo o no las demandas impuestas por ese estándar (Laudan, 2005, p. 103). La razón es que la confianza subjetiva no se mide. Nadie sabe cuánto de confianza es «90%» en términos de la experiencia vivida. Pero si no puede especificarse, tampoco puede verificarse, y si no puede verificarse, no es un estándar sino una excusa.

El punto crítico, que trasciende la academia y toca el núcleo de la controlabilidad judicial, es que para que un estándar funcione efectivamente debe

comunicar algo más que una invitación a decidir conforme a la propia conciencia. Debe decir, de forma precisa, cuándo se ha alcanzado la certeza suficiente. Mientras ese decir quede implícito o privatizado en la mente del juzgador, el derecho a impugnar queda convertido en derecho a adivinar. Las partes no saben qué tenían que probar, y los jueces de apelación no saben qué tenían que revisar.